

포괄임금제와 관련된 실무상 쟁점들에 대한 검토

김 태 욱*

국문초록

포괄임금제에 관한 기본법리를 제시한 것으로 평가되는 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008다6052 판결의 법리가 청구원인이나 공격방법이 무엇인지와 무관하게 포괄임금제 사건에 일률적으로 적용되고 있는데 타당하지 않다. 위 법리가 적용되는 것은 약정한 근로시간을 초과하여 실제 연장근로 등을 했음을 청구의 근거로 하는 유형에 한정되는 것이 타당하다. 소정근로의 제공 여부만 확인하면 되는 수당을 청구하는 사건, 통상임금 재산정에 따른 법정수당 차액을 청구하는 사건, 최저임금법 위반으로 인한 차액 청구 사건은 실제 연장근로시간 등의 산정이 쟁점이 아니므로 위 법리가 적용될 필요가 없다.

한편 포괄임금제가 최저임금법에 위반되는지의 판단 및 그에 따른 차액 산정 시에 일반적인 최저임금법 사건과 같이 간이한 실무상의 방식을 적용하면 오류가 발생하거나 발생할 위험성이 높다. 정액급 포괄임금제의 경우 2018. 12. 31. 이전의 기간에 대한 청구에서, 관련 문헌과 대다수의 하급심이 최저임금법 위반 판단을 위한 비교대상 시급 및 차액 산정 시에 오류를 범해 왔던 것으로 보인다. 2019. 1. 1. 이후의 기간에 대해서도 일반적인 최저임금 사건과 동일하게 계산하면 정액급 포괄임금제는 물론이고 정액수당 포괄임금제에서도 오류가 발생할 가능성이 높다. 포괄임금제가 최저임금법에 위반되는지 여부 및 그로 인한 차액 산정은 최저임금법령이 정하고 있는 원칙적인 방법으로 단계별(비교대상 시급 산정, 최저임금법 위반 및 그에 따른 근로기준법 위반 차액을 구분하여 산정)로 계산해야 오류가 발생하지 않는다.

정액급 포괄임금제의 성립 자체가 부정된 경우 기지급된 정액급여 중 법정수당에 상응하는 금액을 부당이득으로 볼 수 없다. 다른 사정이 증명되지 않는 한 기지급된 정액급여 그 자체를 통상임금(소정근로시간에 대한 대가)으로

* 金兌昱: 법무법인 여는(hopektw@naver.com)

보아야 한다. 특히, 매월의 실제 근로시간이 불규칙함에도 불구하고 매월 동일한 정액급여가 지급된 경우에는 통상임금으로 볼 수밖에 없다. 그러나 사전에 정해진 근로시간 전체에 대한 대가로 지급하였다는 의사가 확인되는 경우에는 기본급(사전에 정한 근로시간 전체에 대한 대가, 다만 가산율은 제외)으로 보아야 할 것이다. 근로시간 산정이 가능함에도 불구하고 정액급 포괄임금약정을 체결하고 그 성립이 인정되는 경우에는 그 사유만으로도 전부 무효라고 봄이 타당하고, 기지급된 정액급여는 포괄임금제의 성립 자체가 부정된 경우와 동일하게 평가할 수 있다. 이와 달리 정액급 포괄임금제의 성립은 인정되나 근로기준법 또는 최저임금법 위반을 이유로 일부 무효가 되는 경우 기지급된 정액급여가 법정수당의 성질을 가지고 있다는 점 자체가 부정되는 것은 아니다.

주제어: 포괄임금제의 효력 판단 방식, 정액수당제와 정액급제 구분, 포괄임금제에서 최저임금법 위반 판단, 기지급된 정액급여의 성질

목 차

- I. 들어가며
- II. 포괄임금제 성립과 효력에 관한 기본 법리
- III. 청구의 근거에 따른 포괄임금제의 효력 판단 방식
- IV. 정액수당제와 정액급제의 구분
- V. 포괄임금제의 최저임금법 위반 판단 및 차액 계산 방법 (정액급제를 중심으로)
- VI. 정액급 포괄임금제가 성립하지 않거나 무효인 경우 이미 지급된 금원의 성질
- VII. 나가며

I. 들어가며

포괄임금제¹⁾는 실제 근로시간을 제한하려는 근로기준법의 취지에 반하고,²⁾ 근로시간을 관리할 사용자의 의무를 면제해 줌으로써 근로자가

해당 포괄임금제가 근로기준법에서 정한 기준에 미달하는 것을 증명하는 것 자체를 어렵게 만드는 등 많은 문제가 존재한다. 특히 정액급 포괄임금제는 기본임금과 법정수당이 구별되지 않기 때문에 실무상 근로기준법상 법정수당이 전부 지급되었음을 전제로 정액급여를 역산하여 기본임금을 구하게 되므로 근로기준법상의 근로시간에 관한 규제를 적용하는 것이 불가능한 경우가 많고, 역산하여 구한 기본임금이 최저임금에 미달³⁾하기 전까지는 법률상 규제가 적용되기 어렵다는 문제도 심각하다. 이러한 포괄임금제에 대해서는 기존에 매우 많은 연구가 있었는데, 이 글에서는 포괄임금제에 관한 선행 연구에서 논의되지 않았던 것으로 보이는 여러 실무상의 문제점들 즉, ① 포괄임금제에 관한 판례 법리가 포괄임금 소송의 청구원인이나 공격방법⁴⁾에 따라 달리 적용될 필요가 있다는 점 ② 정액급 포괄임금제와 정액수당 포괄임금제의 구분 방법, ③ 정액급 포괄임금제 관련 계산상의 여러 쟁점들에 대하여 검토하고자 한다.

1) 대법원 판결은 ‘포괄임금제에 의한 임금 지급계약(대법원 2008다6052 판결 등)’, ‘포괄임금제에 의한 약정(대법원 2023다221359 판결 등)’의 용어를 사용하고 있는데, 모두 포괄하여 ‘포괄임금제’라고 하고 맥락에 따라 ‘포괄임금약정’이라는 용어도 병용한다.

2) 노동법실무연구회, 「근로기준법 주해 Ⅲ」, 박영사, 2025, 318면

3) 장시간 근로를 해야 비교대상 임금의 시간급이 작아져서 최저임금법에 위반될 수 있게 된다(35면의 대법원 2020다300299 판결의 계산식 참조). 결과적으로 사용자는 최저임금법에 위반되기 직전까지 장시간 근로를 시켜도 근로기준법 위반이 아니게 된다.

4) 이 글에서 구분하여 검토하는 유형들이 청구원인, 공격방법 중 어디에 해당하는지는 이 글의 주제와는 직접 관련이 없으므로, 검토를 생략하고, 이하에서는 별도로 구분하여 기재한 부분을 제외하고는 청구원인과 공격방법을 구분하지 않고 모두 ‘청구의 근거’라고만 한다.

II. 포괄임금제 성립과 효력에 관한 기본 법리

1. 포괄임금제의 성립에 관한 기본 법리

대법원도 포괄임금제의 문제점을 인식해서인지 포괄임금제의 성립을 엄격하게 인정하려는 추세로 보인다. 대법원 2008다57852 판결 법리는 포괄임금약정 성립 여부에 관한 일반적인 판단 기준이고, 대법원 2016도 1060 판결 법리는 묵시적 포괄임금 약정의 성립 여부에 관한 판단 기준이다.

[대법원 2009. 12. 10. 선고 2008다57852 판결 (시내버스 운전기사 사안)]⁵⁾

포괄임금제에 관한 약정이 성립하였는지 여부는 근로시간, 근로형태와 업무의 성질, 임금 산정의 단위, 단체협약과 취업규칙의 내용, 동종 사업장의 실태 등 여러 사정을 전체적·종합적으로 고려하여 구체적으로 판단하여야 하며, 비록 개별 사안에서 근로형태나 업무의 성격상 연장·야간·휴일근로가 당연히 예상된다고 하더라도 기본급과는 별도로 연장·야간·휴일근로수당 등을 세부항목으로 명백히 나누어 지급하도록 단체협약이나 취업규칙, 급여규정 등에 정하고 있는 경우는 포괄임금제에 해당하지 아니한다고 할 것이고, 단체협약 등에 일정 근로시간을 초과한 연장근로시간에 대한 합의가 있다거나 기본급에 수당을 포함한 금액을 기준으로 임금인상률을 정하였다는 사정 등을 들어 바로 위와 같은 포괄임금제에 관한 합의가 있다고 선불리 단정할 수는 없다.

[대법원 2016. 10. 13. 선고 2016도1060 판결 (공사현장 철골공 사안)]⁶⁾

단체협약이나 취업규칙 및 근로계약서에 포괄임금이라는 취지를 명

5) 대법원 2011다93858 판결, 대법원 2015다233579 판결 등도 같다.

6) 대법원 2018다206899 판결, 대법원 2019다241516 판결 등도 같다.

시하지 않았음에도 묵시적 합의에 의한 포괄임금약정이 성립하였다고 인정하기 위해서는, 근로형태의 특수성으로 인하여 실제 근로시간을 정확하게 산정하는 것이 곤란하거나 일정한 연장·야간·휴일근로가 예상되는 경우 등 실질적인 필요성이 인정될 뿐 아니라, 근로시간, 정하여진 임금의 형태나 수준 등 제반 사정에 비추어 사용자와 근로자 사이에 정액의 월급여액이나 일당임금 외에 추가로 어떠한 수당도 지급하지 않기로 하거나 특정한 수당을 지급하지 않기로 하는 합의가 있었다고 객관적으로 인정되는 경우이어야 한다.

2. 포괄임금제의 효력에 관한 기본 법리

한편 대법원 2008다6052 판결은 다음과 같은 판단 기준을 제시하였는데, 포괄임금제의 유효성에 관하여 명확한 지침을 제시한 것으로 평가된다.⁷⁾

[대법원 2010. 5. 13. 선고 2008다6052 판결]⁸⁾

[판시 ①] 근로기준법에 의한 임금 지급 원칙

근로기준법 (2007. 1. 26. 법률 제8293호로 개정되기 전의 것) 제24조(현행 법 제17조)는 “사용자는 근로계약 체결시에 근로자에 대하여 임금, 근로시간 기타의 근로조건을 명시하여야 한다. 이 경우 임금의 구성항목, 계산방법 및 지불방법에 관한 사항에 대하여는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 명시하여야 한다”고 규정하고, 같은 법(2007. 4. 11. 법률 제8372호로 전부 개정되기 전의 것) 제55조(현행 법 제56조)는 같은 법 제52조· 제58조 및 제67조 단서의 규정에 의하여 같은 법 제49조· 제50조· 제51조 및 제67조 본문에 정한 기준근로시간을 초과하여 근로한 연장근로와 야간근로(하오 10시부터 상오 6시까지

7) 박순영, 근로기준법상 근로시간의 규제와 포괄임금제, 「대법원판례해설」, 제83호, 법원도서관 2010, 826면; 임상민, 포괄임금제의 성립 및 유효요건, 「인권과 정의」, 제502호, 대한변호사협회, 2021. 12., 102면

8) ①, ②, ③, ④, ⑤ 및 ❶, ❷ 표시 및 밑줄은 판결문에 없으나 이해의 편의를 위해 필자가 부여한 것이다.

사이의 근로) 또는 휴일근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산한 임금을 지급하여야 한다고 규정하고 있는데, 이러한 규정들과 통상임금에 관하여 정하고 있는 근로기준법 시행령 (2007. 6. 29. 대통령령 제20142호로 전부 개정되기 전의 것) 제6조의 규정 등에 의하면, 사용자는 근로계약을 체결함에 있어서 기본임금을 결정하고 이를 기초로 하여 근로자가 실제로 근무한 근로시간에 따라 시간외근로·야간근로·휴일근로 등이 있으면 그에 상응하는 시간외근로수당·야간근로수당·휴일근로수당 등의 법정수당을 산정하여 지급함이 원칙이라 할 것이다.

[판시 ②] 근로시간 산정이 어려운 경우

이러한 원칙적인 임금지급방법은 근로시간 수의 산정을 전제로 한 것인데, 예외적으로 감시단속적 근로 등과 같이 근로시간, 근로형태와 업무의 성질을 고려할 때 근로시간의 산정이 어려운 것으로 인정되는 경우가 있을 수 있고, 이러한 경우에는 사용자와 근로자 사이에 기본임금을 미리 산정하지 아니한 채 법정수당까지 포함된 금액을 월급여액이나 일당임금으로 정하거나(☞① 정액급제) 기본임금을 미리 산정하면서도 법정 제 수당을 구분하지 아니한 채 일정액을 법정 제 수당으로 정하여 이를 근로시간 수에 상관없이 지급하기로 약정(☞② 정액수당제)하는 내용의 이른바 포괄임금제에 의한 임금 지급계약을 체결하더라도 그것이 달리 근로자에게 불이익이 없고 여러 사정에 비추어 정당하다고 인정될 때에는 유효하다 할 것이다(대법원 1997. 4. 25. 선고 95다4056 판결, 대법원 1997. 7. 22. 선고 96다38995 판결, 대법원 1999. 5. 28. 선고 99다2881 판결, 대법원 2002. 6. 14. 선고 2002다16958 판결, 대법원 2005. 8. 19. 선고 2003다66523 판결 등 참조).

[판시 ③] 근로시간 산정이 어렵지 않은 경우

그러나 위와 같이 근로시간의 산정이 어려운 경우가 아니라면 달리 근로기준법상의 근로시간에 관한 규정을 그대로 적용할 수 없다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 앞서 본 바와 같은 근로기준법상의 근로시간에 따른 임금지급의 원칙이 적용되어야 할 것이므로, 이러한 경우에도 근로시간 수에 상관없이 일정액을 법정수당으로 지급하는 내용의 포괄임금제 방식의 임금 지급계약을 체결하는 것(☞② 정액수당제

를 의미)은 그것이 근로기준법이 정한 근로시간에 관한 규제를 위반하는 이상 허용될 수 없다.

[판시 ④] 근로시간 산정이 어렵지 않은 경우 사용자의 정산의무

한편 구 근로기준법 (2007. 4. 11. 법률 제8372호로 전부 개정되기 전의 것) 제22조(현행 법 제15조)에서는 근로기준법에 정한 기준에 미치지 못하는 근로조건을 정한 근로계약은 그 부분에 한하여 무효로 하면서(근로기준법의 강행성) 그 무효로 된 부분은 근로기준법이 정한 기준에 의하도록 정하고 있으므로(근로기준법의 보충성), 근로시간의 산정이 어려운 등의 사정이 없음에도 포괄임금제 방식으로 약정된 경우 그 포괄임금에 포함된 정액의 법정수당이 근로기준법이 정한 기준에 따라 산정된 법정수당에 미달하는 때에는 그에 해당하는 포괄임금제에 의한 임금지급계약 부분은 근로자에게 불이익하여 무효라 할 것이고, 사용자는 근로기준법의 강행성과 보충성 원칙에 의해 근로자에게 그 미달되는 법정수당을 지급할 의무가 있다.

위 판결은 포괄임금계약을 ‘근로시간의 산정이 어려운 경우와 이에 해당하지 않는 경우로 구분하여 유효성을 달리 인정하였다. 정리하면 다음과 같다.

[대법원 2008다6052 판결 요지]

- 근로시간 산정이 어려운 경우(판시 ②) → 근로자에게 불이익이 없고 여러 사정에 비추어 정당하다고 인정될 때에는 유효함
- 근로시간 산정이 어렵지 않은 경우(판시 ③) → 근로기준법이 정한 근로시간에 관한 규제를 위반하는 부분은 효력이 없음 → 근로기준법에 따라 산정한 법정수당과의 차액을 지급할 의무가 있음(판시 ④)

대법원은 위 판결을 통하여 ① 근로시간 산정이 어려운 경우뿐만 아니라 근로시간의 산정이 어렵지 않은 경우에도 포괄임금계약은 성립할 수 있다는 점, ② 근로시간 산정이 어려운 경우에는 근로시간 산정이 가

능함을 전제로 하는 차액 청구가 불가능하지만, 근로시간의 산정이 가능한 경우에는 근로기준법 등이 정한 기준에 미달할 경우 차액을 청구할 수 있음을 명확히 하였다.⁹⁾ 다만 위 대법원 판결이 근로시간의 산정이 어렵지 않은 경우에 체결된 포괄임금계약 중 정액수당제에 대하여는 근로기준법을 기준으로 유효성을 판단할 수 있음을 명확히 하고 있지만,¹⁰⁾ 정액급제의 경우에는 어떠한 기준으로 그 유효성을 판단할 것인지에 대하여 명시적으로 판단하지 않았다. 위 대법원 판결은 차액에 대한 정산 청구를 부정한 기존의 판례(대법원 95다4056판결, 대법원 2002다16958판결)는 근로시간의 산정이 어려운 경우에 차액 청구를 인정할 수 없다는 취지여서 근로시간의 산정이 어렵지 않은 경우에 관한 위와 같은 법리가 기존의 판례와 저촉되는 것은 아니라는 것도 부가적으로 판시하였다.

한편 위 대법원 판결이 포괄임금제의 유효성 판단 기준으로 제시한 “근로시간 산정이 어려운 경우”의 의미에 대하여 근로시간 산정이 어렵다면 차액 청구가 불가능하다는 의미라는 견해,¹¹⁾ 근로시간 산정이 어려운 경우와 불가능한 경우는 다름을 전제로 포괄임금제가 유효한 것은 근로계약 당시, 근로제공 시, 임금 지급 시에 일관하여 근로시간 산정이 불가능한 경우로 한정 해석해야 한다는 견해¹²⁾ 등이 있고, 일부 하급심 판결¹³⁾은 “근로시간 산정이 어려운 경우”를 근로시간의 산정이 물리적·

9) 박순영, 앞의 글, 821~826면

10) 대법원 2008다6052 판결 사안 자체가 정액수당 포괄임금제 사안이다.

11) 박순영, 앞의 글, 821면

12) 임상민, 앞의 글, 109면

13) 서울고등법원 2021. 7. 27. 선고 2020나2015988 판결(미상고 확정) 「통신기술과 영상장비가 비약적으로 발달하고, CCTV나 위치추적시스템 등이 고도화된 점을 고려하면 근로시간의 산정이 불가능한 영역이란 사실상 거의 상정하기 어렵다. 이는 포괄임금제가 허용되는 전형적인 업무인 감시·단속적 업무에서도 마찬가지이다. 그렇다면 포괄임금제가 허용되는 업무를 엄격하게 제한하여야 한다는 입장에 서더라도 근로시간의 산정이 ‘어려운’ 경우를 근로시간의 산정이 물리적·기술적으로 불가능한 경우로 한정할 수는 없다. 오히려 이 사건에서 항만하역근로자와 피고가 일반적인 근로계약처럼 소정근로시간을 미리 약정하고, 실제 근로시간을 측정한 후 그 시간이 소정근로시간을 초과할 때 그 초과분에 대해

기술적으로 불가능한 경우로 한정할 수는 없고 상당히 곤란한 경우도 포함된다고 판단하기도 하였다.

Ⅲ. 청구의 근거에 따른 포괄임금제의 효력 판단 방식

결론적으로 말하면 법원은 리딩케이스인 대법원 2008다6052 판결의 법리를 모든 유형의 포괄임금 사건에 일률적으로 적용하고 있는 것으로 보이나, 이는 타당하지 않다고 생각한다. 후술하는 바와 같이 위 법리는 실제 연장근로시간 등¹⁴⁾이 포괄임금 산정의 전제가 된 시간보다 더 많음을 이유로 추가 법정수당을 청구하는 경우(①번 유형)에만 적용된다고 보아야 한다. 이하에서는 청구의 근거에 따라 포괄임금제의 효력 판단 방식을 검토한다.

1. ①번 유형: 약정한 근로시간을 초과한 실제 근로시간에 대한 법정수당 청구

(1) 개요

포괄임금제 관련 논쟁의 본령으로 포괄임금제가 쟁점이 되었던 과거 판결들 상당수¹⁵⁾가 ①번 유형에 해당한다. 이 유형의 쟁점은 「근로시간」

서 법정수당을 계산, 지급하는 방식으로 임금을 지급한다면, 앞서 본 항만하역 근로자의 실 근로시간, 근로형태와 업무의 성질, 동종 사업장의 실태 등에 비추어 사전에 임금 산정의 단위에 해당하는 소정근로시간 및 기본임금의 적정한 기준을 세우기가 상당히 곤란하고, 근로자들이 매월 받는 임금액 간에 격차도 클 것으로 예상되므로, 항만하역근로자들의 업무는 근로시간의 산정이 ‘어려운’ 경우에 해당한다고 봄이 상당하다.」

¹⁴⁾ 연장, 야간, 휴일근로시간 등 포괄임금 산정의 대상이 된 근로시간을 의미한다.

¹⁵⁾ 대법원 2016도1060 판결, 대법원 2014다234971 판결, 대법원 2019다241516 판결 등 다수의 대법원 판결.

산정에 관한 것으로서 포괄임금 산정의 기초가 된 근로시간을 초과하여 근로하였다는 것이 증명되어야 인용이 가능하므로 대법원 2008다6052 판결이 「근로시간 산정이 어려운 경우」와 「근로시간 산정이 가능한 경우」를 구분하여 법리를 실시하게 된 근거가 되었다고 보인다. 위 대법원 판결 스스로 “근로기준법이 정한 근로시간에 관한 규제를 위반하는 이상 허용될 수 없다”고 밝히고 있기도 하다. 대법원 2008다6052 판결은 근로시간 산정이 가능한 정액수당 포괄임금제의 경우 차액 청구가 가능¹⁶⁾하다고 명시하고 있지만, 근로시간 산정이 가능한 정액급 포괄임금제에 관해서는 명확히 판시하지 않았는데 차액 청구가 가능하다고 보아야 한다(아래 (2)항 참조).

(2) 정액급 포괄임금제의 경우에도 근로기준법 위반으로 인한 차액 청구가 가능한 경우

근로시간 산정이 가능한 정액급 포괄임금제의 경우 포괄임금제의 근거(단체협약, 취업규칙, 근로계약 등¹⁷⁾)를 살펴 포괄임금제가 포괄하는 근로시간의 범위를 한정하고 그 범위를 초과하는 근로를 했음이 증명된다면 그 증명된 추가 근로시간에 대해서는 법정수당을 지급¹⁸⁾하는 것이 타당하다.

1) 대법원 2014. 6. 26. 선고 2014도4092 판결

대법원 2014도4092 판결 사안은 일식당 주방장으로 근무한 근로자에게 임금약정에서 정한 연장근로시간에 대하여 연장근로수당¹⁹⁾을 지급하

¹⁶⁾ 대법원 2008다6052 판결 사안 자체가 정액수당 포괄임금제 사안이다.

¹⁷⁾ 단체협약, 취업규칙, 근로계약 등에 명시적인 규정이 없더라도 묵시적인 의사의 해석 또는 보충적 해석을 통해서도 포괄임금제가 포괄하는 근로시간의 범위가 한정되는 경우도 있을 것이다.

¹⁸⁾ 예정한 근로시간(가산을 반영)을 기초로 정액급 임금을 역산하여 기본임금을 구한 후, 예정한 근로시간을 초과한 부분에 대해서는 위 기본임금을 기초로 산정한 법정수당을 추가로 지급할 것을 명하는 것이 가능하다.

지 않았다는 이유로 공소제기된 사안이다. 대법원은 약정한 근로시간 내의 연장근로(1일 3시간)에 대한 임금이 지급(·포괄임금약정 유효)되었다고 보아 해당 부분을 무죄²⁰⁾ 취지로 파기하였으나 「이 사건 임금약정에서 정한 월급여액에는 약정 근로시간 한도 내에서의 법정수당이 포함되어 있으므로」라고 하여 정액급 포괄임금약정에 포함된 법정수당은 약정한 근로시간의 한도 이내에 한정된다고 판시하였다.

[대법원 2014. 6. 26. 선고 2014도4092 판결 (일식당 주방장 사안)]

2. 제1심이 적법하게 채택한 증거들에 의하면, 피고인이 운영하는 일식당의 주방장으로 근무한 E은 피고인과 근로계약을 체결하면서 근로시간을 오전 9시부터 오후 10시까지(주 1회 휴일)로 정하고 이에 대하여 일정액의 월급여를 지급받기로 약정(이하 ‘이 사건 임금약정’이라 한다)한 사실을 알 수 있다. 이와 함께 기록에 나타난 이 사건 임금약정의 체결 경위와 약정한 임금의 수준, 일식당의 영업 형태, E에 대한 구체적인 임금지급 내역과 임금지급 전후의 제반 사정 등을 종합하여 보면, 이 사건 임금약정은 E의 업무에 관하여 근로시간의 산정이 어려운 경우에 해당하지 아니함에도 약정한 오전 9시부터 오후 10시까지의 근로시간 한도 내에서의 법정수당을 포함하여 월급여액을 정한 포괄임금제 방식의 임금 지급계약에 해당하는 것으로 보인다.

이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 임금약정에서 정한 월급여액에는 약정 근로시간 한도 내에서의 법정수당이 포함되어 있으므로 근로시간의 산정이 어렵지 아니한 이 사건에서는 근로기준법이 정한 근로시간에 관한 규제를 위반하는 부분에 한하여 추가로 법정수당을 지급할 의무가 있다고 할 것이다

19) 근로자의 날에 대한 유급휴일근로수당 미지급도 포함되어 있으나 본 발표와는 직접 관련이 없으므로 생략한다.

20) 정액급 포괄임금약정에서 약정한 근로시간을 초과하는 시간을 근로했다는 것이 공소제기 내용에는 포함되지 않았던 것으로 보인다.

2) 대법원 1992. 7. 14. 선고 91다37256 판결

대법원 91다37256 판결 사안은 정액급 포괄임금 계약을 체결한 시외버스 운전기사들이 약정한 연장근로시간을 초과하여 근로하였음을 전제로 연장근로수당을 청구한 사안이다. 대법원은 포괄임금약정에 포함된 법정수당은 약정한 근로시간의 한도 이내에 한정되므로 원고들의 실제 근로시간이 약정한 연장근로시간을 초과하는지를 심리하여 그 초과분에 대해서는 원고들 청구가 인정되어야 한다는 취지(아래 ①, ②번 표시 참조)²¹⁾로 판시하면서 원심을 파기하였다.

[대법원 1992. 7. 14. 선고 91다37256 판결 (시외버스 운전기사 사안)]

2. 근로계약을 체결할 때에 기본임금을 미리 산정하지 않은 채 제수당을 합한 금액을 월급여액이나 일당임금으로 정하는 이른바 포괄임금제의 임금체계에 의한 임금의 지급이 근로자에게 불이익이 없고 정당하다고 인정될 수 있는 것은 근무형태의 특성 그 자체 때문만은 아니고, 포괄임금제의 임금체계에 의하여 임금이 지급되었다고 하더라도 그 지급된 임금에는 법정의 제수당이 미리 포함되어 있다는 사실에 기인하는 것이라고 볼 것(☞①번)이다.

3. 그러나 이 사건에서 보건대, 을 제1호증(임금협정서), 을 제2호증(단체협약서)의 각 기재에 의하면 운전사, 안내원 등의 일당 중에는 기본급 및 연장근로수당과 월 25일 이내에 해당하는 주휴수당이 포함되어 있다는 것이고, 근로시간은 1일 8시간으로 하되 노사간 합의에 따라 1일 2시간 이내에서 연장근로를 할 수도 있고, 근로일수는 월 25일로 한다고 규정되어 있는 바이어서(임금협정서 중의 서문과 제4항, 단체협약서 중 제31조, 제32조), 이러한 내용과 원심이 인정한 임금협정 및 단체협약의 내용에 비추어 보면, 피고 회사가 위 임금협정이나 단체협약에 근거하여 원고와 선정자들에게 지급한 일당에는 근로기준법상 기준근로시간인 1일 8시간과 2시간의 연장근로를 합한 10시간씩 월 25일 근로할 것을 만근(만근)으로 삼아 그 한도 내에서의 연장근로수당과 주휴근로수당만이 포함되어 있다고 보는 것이 타당하고, 거기

21) ①, ② 표시는 필자가 임의로 추가한 것이다.

에 제한없는 연장근로수당 일체가 포함되어 있다고 보기는 어렵다.(당원 1982.12.28. 선고 80다3120 판결; 1991.4.23. 선고 89다카32118 판결 각 참조) (☞②번)

4. 그러므로 원심으로서는 원고와 선정자들의 실근로시간수를 살펴 보아 그것이 1일 평균 10시간씩 월 25일 만근한 한도를 초과하는 것인지 여부를 심리하여야 할 것인데 원심이 여기에 이르지 아니한 것은 심리미진이나 이유불비의 위법이 있다고 아니할 수 없고, 논지는 이 점을 지적하는 범위 안에서 이유 있다.

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

(3) 구체적인 실제 근로시간 산정을 전제로 하지 않는 청구의 경우

한편, 대법원은 연월차휴가수당²²⁾과 야간근로수당²³⁾도 포괄임금약정의 대상이 된다고 보고 있다. 이 중 특히 연차(월차)휴가수당에 대해서는 임금산정 기간의 근로 제공을 대상으로 한 것이 아니라 직전 연도의 근로제공 비율 및 근속연수에 따라 지급되는 후불적 보상의 성격이 강하고, 휴가권이나 그에 따른 수당청구권의 유무나 정도도 근로자의 청구 여부에 의존하는 등 다른 법정수당과는 성격을 달리한다는 점을 근거로,²⁴⁾ 휴가의 청구가 실질적으로 제약받음으로써 휴가제도 자체가 무의미해지며 연차휴가사용촉진제도를 도입한 것과도 모순된다는 점 등을 근거로²⁵⁾ 포괄임금제에 포함될 수 없다는 견해가 있다. 타당한 견해라고 생각된다.

연차휴가수당과 소정근로시간 내의 야간근로에 대한 가산수당에 대한

²²⁾ 대법원 2023. 11. 30. 선고 2019다29778 판결.

²³⁾ 대법원 2002. 6. 14. 선고 2002다16958 판결.

²⁴⁾ 강성태, 포괄임금제의 노동법적 검토, 「노동법연구」, 제26호, 서울대학교 노동법연구회, 2009, 273면

²⁵⁾ 하갑래, 포괄임금제의 내용과 한계, 「노동법학」, 제29호, 한국노동법학회, 2009, 339면.

포괄임금약정의 성립을 긍정하더라도, 유효성을 판단하는 기준은 대법원 2008다6052 판결과 같이 근로시간 산정이 가능한 경우와 어려운 경우로 구분할 필요는 없다. 해당 근로자가 기준 일수 이상 출근하여 연차휴가가 발생하였는데 휴가를 사용하지 않고 근로를 제공했거나(☞연차휴가수당) 결근, 조퇴 등을 하지 않고 정해진 근무일정에 따라 소정근로를 제공하였다면(☞소정근로시간 내의 야간근로) 발생하는 수당들은 실제 근로시간 산정이 가능한지 여부와 직접 관련이 없기 때문이다. 통상적인 근로관계에서 근로자의 휴가 사용 여부 또는 소정근로의 제공 여부 자체(☞결근, 조퇴 여부)를 확인하기 어려운 경우란 상정하기 어려워 보인다.²⁶⁾ 따라서 특별한 사정이 없는 한 일반적인 연차휴가수당청구 또는 소정근로내의 야간근로에 대한 가산임금 청구소송과 마찬가지로 심리하면 충분하다. 즉, 기준 일수 이상 출근하여 연차휴가가 발생한 사실²⁷⁾(☞연차휴가수당) 또는 소정근로내의 야간근로를 제공한 사실(☞소정근로내의 야간근로가산수당)을 근로자가 증명하고 사용자가 다른 항변 사유가 없다면 해당 청구를 인용하는 것이 타당하다. 포괄임금약정을 체결했다는 사정 그 자체만으로는 유효한 항변 사유가 될 수 없다. 이와 같이 심리 방식이 일반적인 연차휴가수당 또는 소정근로 내의 야간근로가산수당 청구와 다르지 않다고 본다면 이를 포괄임금약정에 포함할 실익도 없다고 보인다.

26) 재량근로제를 적법하게 도입하면서 근로자대표와의 서면 합의 시에 소정근로일의 출근 여부까지도 근로자의 재량에 맡기는 경우에는 소정 근로의 제공 여부 자체를 확인하기 어려울 수도 있는데, 이 경우 사용자는 출퇴근 관리를 별도로 하지 않으므로 소정 근로일 전체를 출근한 것으로 본다(고용노동부, 「유연근로시간제 가이드」, 2018. 6., 87면). 따라서 여기에 대법원 2008다6052 판결 법리를 적용할 이유는 없다.

27) 연차휴가수당청구의 경우 근로자에게 연차휴가 미사용일수에 대한 증명책임이 있다는 하급심 판결(서울남부지방법원 2019가합 116222 판결, 서울중앙지방법원 2020가단5081423 판결)과 사용자가 연차휴가 사용일수에 대한 증명책임이 있다는 하급심 판결(대구고등법원 2023나14927 판결, 수원지방법원 2020가합 13147 판결) 등이 엇갈리고 있다. 이 글에서는 상세히 다루지 않는다.

2. ②번 유형: 통상임금 재산정으로 인한 법정수당 추가 청구

통상임금 재산정으로 인한 법정수당 차액 청구 소송²⁸⁾의 경우 대법원은 ㉠ 포괄임금약정의 성립이 인정되고 실제 근로시간 산정이 어려워 포괄임금약정이 유효하다고 판단되면 근로자들의 청구를 기각하고 있다(대법원 2015다8803 판결, 대법원 2016다54995 판결, 등), ㉡ 포괄임금약정 성립이 인정되고 실제 근로시간 산정이 가능하면 앞서 본 ㉠번 유형과 마찬가지로 차액 청구를 인용하고, ㉢ 포괄임금약정의 성립이 부정되면 일반적인 통상임금 소송과 마찬가지로 심리하는 것으로 보인다(대법원 2015다73067 전원합의체 판결²⁹⁾ 등).

(1) 포괄임금제 성립이 부정되는 경우 보장시간약정에 대한 심리 필요

②번 유형은 보장시간약정에 따른 청구와 유사한 측면이 있다. 즉, 대법원은 여러 판결³⁰⁾을 통해서 “근무형태나 근무환경의 특성 등을 감안하여 노사 간에 실제의 연장근로시간 또는 휴일근로시간과 관계없이 일정 시간을 연장근로시간 또는 휴일근로시간으로 간주하기로 합의하였다면 사용자로서는 근로자의 실제 연장근로시간 또는 휴일근로시간이 위 합의한 시간에 미달함을 이유로 근로시간을 다투는 것이 허용되지 않는다.”고 하여 재산정한 통상임금을 기초로 한 금액에 보장시간약정에 따른 차액 청구를 인용해 왔다. 포괄임금약정과 보장시간약정은 유사해 보이는 측면은 있지만, 포괄임금약정은 “임금(법정수당)”에 관한 약정인 반

²⁸⁾ 대법원 2008다57852 판결, 대법원 2015다233579 판결, 대법원 2015다8803 판결 등 다수.

²⁹⁾ 버스 기사들이 근속수당 등이 통상임금에 추가되어야 함을 전제로 통상임금을 재산정하여 법정수당 차액을 청구한 소송이다. 통상임금 산정 방법에 관하여 전원합의체 판결 선고가 이루어졌으나 포괄임금제에 관해서는 그 성립을 부정한 원심을 단순 수긍하였다.

³⁰⁾ 대법원 2018다244631 판결, 대법원 2011다37858 판결, 대법원 2006다81523 판결 등 다수

면, 보장시간약정은 “근로시간”에 관한 약정이라는 점에서 개념상 구분된다.³¹⁾ 따라서 포괄임금약정의 성립 자체가 부정되는 ②의 ㉠유형의 경우 보장시간약정에 해당하는지에 대한 심리가 추가로 이루어질 필요가 있다. 대법원 2008다57852 판결(시내버스 운전기사 사안) 사안에서도 대법원은 포괄임금 약정의 성립을 부정하였는데, 환송 후 원심(대구지방법원 2009나20060 판결)은 보장시간약정이 성립하였다고 판단하면서 보장시간약정에 대응하는 법정수당 차액 청구를 인용하였고, 해당 쟁점은 재상고심(대법원 2011다26537 판결)으로 확정되었다.³²⁾

(2) 포괄임금제 성립이 인정되는 경우에도 ①번 유형과는 다르게 판단할 필요성이 존재함

한편, 포괄임금제 성립이 인정되는 ②의 ㉠유형의 경우 대법원은 이를 ①번 유형과 동일하게 취급하고 있는 것으로 보인다. 예를 들어 대법원 2016다54995 판결은 버스 기사들이 근속수당, 상여금 등이 통상임금에 추가되어야 함을 전제로 통상임금을 재산정하여 연장·야간·휴일근로수당과 연차휴가수당 차액을 청구한 사건이다. 원심(서울고등법원 2015나20799 판결)은 근속수당 등 일부 항목이 법정 통상임금에 해당한다고 보

31) 대법원 2010다91046 판결은 「단체협약 등에 일정 근로시간을 초과한 연장근로시간에 대한 합의가 있거나 기본급에 수당을 포함한 금액을 기준으로 임금인상률을 정하였다는 사정 등을 들어 바로 위와 같은 포괄임금제에 관한 합의가 있다고 선불리 단정할 수는 없다(대법원 2009. 12. 10. 선고 2008다57852 판결 참조)」고 하여 보장시간약정(=일정 근로시간을 초과한 연장근로시간에 대한 합의)와 포괄임금 합의를 구분하였다.

대법원 2011다27769 판결은 환경미화원에게 지급되는 임금 산정의 기준이 되는 행정자치부 지침은 시간외근무수당의 지급방법에 관하여 ‘1일 2시간, 월 30일을 기준으로 하되, 복무규정상외의 근무일에 병가, 결근, 휴가 등 실제로 근무하지 않은 일수를 제외함(단, 유급휴일은 포함)’이라고 규정하고 있는데 이는 근로시간 등에 대한 사전 합의이고 포괄임금제의 합의라고 볼 수 없다고 본 원심을 수긍하였다.

32) 통상임금 관련 다른 쟁점으로 다시 파기되어 최종적으로 대법원 2014다22598 판결로 확정되었다.

아 연차휴가수당 차액 청구를 일부 인용하였으나, 연장·야간·휴일근로수당에 대해서는 실제 근로시간 산정이 어렵다는 점을 핵심적³³⁾인 근거로 삼아 유효한 포괄임금제가 성립하였다고 보아 청구를 전부 기각하였다. 대법원도 포괄임금약정이 유효하다는 원심을 수긍하면서 추가적인 근거를 제시하지 않고 연장·야간·휴일근로수당에 관한 상고이유를 배척하였다.

그러나 ②의 ㉠유형의 경우를 ①번 유형과 동일하게 처리하는 것이 타당한지는 의문이다. 포괄임금제에 관한 법리는 법률상 근거가 없음에도 불구하고 근로시간 산정의 어려움이라는 사정을 주요하게 고려하여 법원이 인정한 것이지 통상임금을 법정 기준보다 적게 지급하는 것을 용인해 주는 것까지 포함하는 것은 아니기 때문이다. 리딩케이스인 대법원 2008다6052 판결도 “근로기준법이 정한 근로시간에 관한 규제를 위반하는 이상 허용될 수 없다”고 하고 있는데 통상임금을 법정 기준에 미달하여 산정한 것은 근로시간과는 무관한 것이다.

또한 ②의 ㉠유형의 경우에는 근로자들이 종전의 약정 근로시간을 전제로 통상임금만을 재산정하여 청구하는 경우가 대부분이므로 ①번 유형과는 그 국면도 다르다. 즉, ①번 유형은 약정한 연장근로시간보다 더 많이 근로하였음을 ‘근로자들’이 다투는 국면이고, 보장시간약정은 약정한 연장근로시간보다 더 적게 근로하였음을 ‘사용자’가 다투는 국면이지만, ②의 ㉠유형의 국면은 포괄임금약정이 성립한 상태에서 통상임금 재산정만을 주장하는 경우가 대부분이다. 이러한 경우에는 재산정한 통상시급을 기초로 종전에 해당 근로자에게 적용된 연장근로시간 등을 곱하여 차액을 인정하는 것이 타당하다고 보인다.

보장시간약정과 달리 포괄임금제는 “임금”에 관한 합의이므로 법정수당 총액을 기준으로 판단해야 하고 통상임금 부분만 취사선택하여 차액을 청구할 수 없다고 하더라도 현재의 판단 방식이 타당하지 않음은 마찬가지이다. 이른바 취사선택 금지론에 따르면 비교대상이 되는 “법정수

³³⁾ 근로자들에게 불이익하지도 않다고 판단하였는데 그 가장 중요한 근거 역시 실제 근로시간 산정이 어렵다는 점이다.

당 총액”을 계산할 때 「④ 법정 통상임금 × ⑥ 실제 연장근로시간」과 「③ 약정 통상임금 × ④ 약정 연장근로시간」을 비교하게 된다. 포괄임금 약정이 성립하였다고 법원이 인정하는 경우(②의 ⑦유형) 사용자는 근로시간 관리를 하지 않아 왔던 경우가 대부분일 것이어서 근로자들이 실제 연장근로시간(⑥)을 증명하기는 매우 어려울 것이다. 따라서 포괄임금 약정이 성립하였는데 사용자가 근로자들이 약정 연장근로시간보다 더 적게 근로했다고 다투는 경우 실제 연장근로시간(⑥)을 사용자가 증명하도록 하는 것이 공평의 원칙에 부합한다. 사용자가 약정 연장근로시간(④)보다 적은 실제 연장근로시간(⑥)을 증명했다면 법원은 「④ 법정 통상임금 × ⑥ 실제 연장근로시간」과 「③ 약정 통상임금 × ④ 약정 연장근로시간」을 비교하여 차액이 발생하는 경우에 그 차액을 인정하고, 사용자가 ⑥를 증명하지 못하면 법원은 「④ 법정 통상임금 × ④ 약정 연장근로시간」을 인용하면 된다. 보장시간약정과 다른 점은 사용자가 약정 연장근로시간(④)보다 적은 실제 연장근로시간(⑥)을 증명³⁴⁾하여 다룰 수 있다는 점이다.

이에 대하여 통상임금 재산정만이 청구의 근거라고 하더라도 결국 청구하는 것은 법정수당이고, 그렇다면 포괄임금약정 자체의 유·무효를 판단하는 기본 법리(대법원 2008다6052 판결)에 따라야 한다고 반론할 수도 있겠으나, 타당하지 않다. 동일한 임금청구권이라고 하더라도 그것을 무효로 하는 청구원인 또는 공격방법은 여러 가지가 있을 수 있고, 그에 따라 적용되는 법리가 다른 것은 당연하다. 예를 들어 동일한 기간의 임금에 대하여 ① 근로계약에 미달한 임금을 지급하였음을 원인으로 한 청구, ② 연령차별을 원인으로 한 청구, ③ 최저임금법 위반을 원인으로 한 청구, ④ 통상임금 과소 산정을 원인으로 한 청구, ⑤ 실제 연장근로에 따른 법정수당보다 과소 지급되었음을 원인으로 한 청구는 각각 별도의 청구원인 또는 공격방법일 수 있고 그에 적용되는 법리는 동일하

34) 연장근로에 대한 사전 약정이 존재하므로 그 약정에 반하는 사실을 사용자가 본증으로 증명해야 할 것이다.

지 않다. 따라서 ①~④은 인정되지만 ⑤는 부정되는 경우도 충분히 있을 수 있다. 다만 근로자들이 이를 여러 건의 소송으로 나누어 진행하는 경우 중복제소인지에 관한 소송법상 검토가 필요할 뿐이다.

3. ③번 유형: 최저임금법 위반으로 인한 차액 청구

최저임금법 위반 여부는 연장근로 등 실제 근로시간이 아닌 소정근로시간을 기준으로 판단하는 것이므로 최저임금법 위반 여부가 쟁점이 된 사안에서 대법원 2008다6052 판결의 법리가 그대로 적용되는 것은 타당하지 않다.

물론 뒤에서 보는 바와 같이 ㉠ 정액수당제인지, 정액급제인지에 따라 또는 ㉡ 정액급제인 경우 그 유효 여부에 따라 최저임금법 위반 여부를 판단하는 방법이 달라지기는 한다. 그러나 위 ㉠은 의사해석을 통해 포괄임금제의 성립 여부 및 그 유형을 판단한 후 비교대상 임금을 산정하는 문제이므로 앞에서 본 포괄임금 “성립”에 관한 법리(대법원 2008다57852 판결, 대법원 2016도1060 판결 등)가 적용될 문제이지 실제 근로시간 산정이 핵심인 포괄임금제 유·무효 법리(대법원 2008다6052 판결)와는 기본적으로 무관하다.

정액급제(㉡)의 경우에도 사전에 약정한 연장근로시간 등은 다투지 않으면서 최저임금 미달 여부만 다투는 경우도 충분히 있을 수 있으므로 위 대법원 2008다6052 판결의 법리를 그대로 적용할 필요는 없다. 대법원 2008다6052 판결은 근로시간 산정이 어렵지 않음에도 불구하고 정액급 포괄임금약정을 체결한 경우 그것이 항상 무효라고 한 것이 아니라 “근로자에게 불이익이 없고 여러 사정에 비추어 정당하다고 인정될 때에는 유효하다 할 것”이라고 하였다. 따라서 위 법리에 의할 경우 무엇을 기준으로 불이익을 판단하는지에 따라 유·무효가 달라지게 되는데 최저임금법 위반 여부는 실제 근로시간과 무관하게 불이익 여부 판단이 가능하기 때문에 대법원 2008다6052 판결의 법리를 그대로 적용할 필요

는 없는 것이다. 그런데 일부 대법원 판결들(대법원 2014도8873 판결³⁵⁾ 등)은 최저임금법 위반 여부를 판단하는 데에서도 근로시간 산정이 어려운지 여부를 주요 쟁점으로 판단하고 있어서 타당하지 않다.

근로시간 산정이 불가능하거나 어려운 가장 대표적인 사례가 감시·단속적 근로이다. 감시·단속적 근로는 ㉠ 고용노동부 장관이 승인을 받으면 연장·야간·휴일근로수당 등이 발생하지 않고 ㉡ 유효한 포괄임금제가 쉽게 인정되는 등 근로기준법상의 근로시간, 휴게시간, 연장·야간·휴일근로수당 등에 있어서는 특별한 취급을 받고 있다고 볼 수 있으나, 최저임금에 관해서는 그렇지 않다. 감시·단속 근로자에게 최저임금법이 2007년 ~ 2014년은 최저임금을 일부 감액하여, 2015년부터는 사실상³⁶⁾ 전면적으로 적용되다가 2017. 9. 19. 감액 지급 규정 자체가 삭제되어 전면적으로 적용되고 있다. 따라서 포괄임금약정이 성립한 경우에도 최저임금법 위반 여부를 판단할 때에 실제 근로시간 산정이 가능한지를 판단할 필요가 없다.

이러한 점을 고려해서인지 최근 선고된 대법원 2020다300299 판결³⁷⁾은 근로시간 산정이 어려운 경우에도 최저임금법 위반 여부 판단이 가능할 수 있다고 명시적으로 판시하였다.

35) 대법원 2014도8873 판결은 결과적으로 포괄임금제를 무효라고 보아 최저임금법 및 근로기준법 위반을 모두 인정한 원심을 수긍하여 그 결론은 타당하다. 그러나 문제되는 근로기준법 위반은 최저임금법 위반으로 인한 것이었으므로 결국 핵심은 최저임금법 위반이었는데 최저임금법 위반 판단을 위해 실제 근로제공이 가능했는지 여부를 전제로서 판단할 이유는 없었다고 보인다. 위 대법원 판결의 다른 쟁점(제2 상고이유)에서 휴게시간이 몇시간이었는지를 다투기는 했으나 이는 최저임금법 위반 쟁점과는 무관한 쟁점이다. 원심이나 대법원이 실제 근로시간 산정이 가능한지 여부를 판단한 것은 포괄임금제가 최저임금법 위반 인지를 판단하는 제1 상고이유에서이지, 휴게시간이 몇 시간이었는지를 다투는 제2 상고이유에서가 아니다.

36) 2015. 1. 1.부터는 대통령령에서 감시·단속 근로자에 대한 감액 비율을 정하지 않았다.

37) IV항에서 검토하는 판결인데, 사전에 약정한 연장근로시간 등을 알 수 있어 역산하여 기본임금을 산정하는 것이 가능한 사안이다.

[대법원 2024. 12. 26. 선고 2020다300299 판결]

감시 또는 단속적 근로 등과 같이 근로시간, 근로형태와 업무의 성질을 고려할 때 근로시간의 산정이 어려운 경우 포괄임금계약을 체결하더라도 그것이 달리 근로자에게 불이익이 없고 여러 사정에 비추어 정당하다고 인정될 때에는 유효하다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008다6052 판결, 대법원 2016. 9. 8. 선고 2014도8873 판결 등 참조). 그러나 포괄임금계약에 따라 지급된 임금이 최저임금에 미달하는 때에는 포괄임금계약이 유효하다고 볼 수 없고, 사용자는 그 미달액을 지급하여야 한다. 이때 최저임금 미달 여부의 판단을 위한 비교대상 지급의 산정 방법은 다음과 같다.

4. 소결

리딩케이스인 대법원 2008다6052 판결의 법리는 실제 연장근로시간 등을 다루는 ①번 유형에 한정하여 적용되는 것이 타당하다. 통상임금 재산정(②번 유형) 또는 최저임금법 위반(③번 유형)으로 인한 차액 청구 유형의 경우에는 위 리딩케이스의 법리가 적용될 국면은 아니다.

Ⅳ. 정액수당제와 정액급제의 구분

1. 개요

앞에서 본 바와 같이 정액수당제와 정액급제는 개념상 구분될 뿐 아니라 근로기준법 위반에 따른 차액 청구 가능 여부, 최저임금법 위반 판단 방법 등 여러 측면에서 실질적인 차이가 있다. 그런데 다수의 판결들이 ① 해당 사건에서 문제되는 포괄임금약정이 정액수당제인지 정액급제인지를 명확히 구별하지 않는 경우가 많고, ② 일단 포괄임금약정이 성립하였다고 판단되면 어떤 유형인지와 무관하게 정액급제 방식으로

역산하여 최저임금법 위반 여부를 판단하는 경우도 적지 않으며,³⁸⁾ ③ 판결 이유에서 정액수당제라고 명시하였음에도 불구하고 최저임금법 위반 여부는 기준임금이 아니라 급여 총액을 기준으로 판단한 것으로 보이는 사례³⁹⁾도 있다.

정액수당제와 정액급제의 구분에 대하여 대법원은 “기준 임금을 미리 정했는지 여부”라는 기준을 제시하고 있을 뿐이고, 나머지는 전부 개별 사건에서의 포섭 판단 사항이다. 그러나 어떤 유형의 포괄임금제인지 여부에 따라 실질적인 차이가 존재하므로 이하에서는 원심에서 정액수당제라고 판단했으나(그러면서도 최저임금법 위반 여부는 마치 정액급 포괄임금제처럼 역산하여 판단함), 대법원이 정액급 포괄임금제라고 판단한 대법원 2024. 12. 26. 선고 2020다300299 판결을 간략하게 검토한다.

2. 대법원 2020다300299 판결 검토⁴⁰⁾

원고들은 2018. 5. 21. 업무 수행 중 사고로 사망한 망인의 상속인들로서 사용자인 피고들에 대하여 망인의 손해(일실수입, 일실퇴직금 상당액)배상을 청구하였다. 원심은 이 사건 사고 당시 정액수당제 포괄임금 약정이 성립하였는데 최저임금에 미달하였다고 판단하였다. 원심이 인정한 사실관계에 의하면 근로계약서와 임금대장의 내용은 다음과 같은 것으로 보인다.

38) 서울북부지방법원 2022나34914 판결(대법원 2024다269235 심리불속행 기각 확정), 부산지방법원 2021나68285 판결 (상고이유서 부제출 확정), 부산지방법원 2019나49427 판결 (미상고 확정), 수원지방법원 2018나91575 판결 (미상고 확정) 등.

39) 대전지방법원 2013노2962, 3078(병합) 판결 (대법원 2014도12044판결로 확정).

40) 포괄임금제가 성립하였다고 볼 수 있는지 의문도 있으나, 포괄임금제 성립에 대해서는 다툼이 없었던 사안으로 보인다. 또한 본문에서 서술한 바와 같이 각종 법정수당의 구분은 형식적이었던 것으로 보인다.

■ 2016년 근로계약서의 내용

제5조 (임금)

1. 항목	2. 금액	3. 산출근거
월간급여	2,700,000원	기본급 + 고정연장근로수당
<월간급여 항목별 세부내역>		
기본급[주휴수당포함]	1,260,270원	시간급 × 209시간
고정연장근로수당	1,409,580원	시간급 × 155 × 1.5
고정야간근로수당	30,150원	시간급 × 10 × 0.5

제7조 (근로시간 및 휴게시간)⁴¹⁾ 1일 근로시간을 9시간으로, 1주 근로시간을 54시간으로 정하고 있음

■ 임금대장에 기재된 보수 총액

- 2016년 월 270만 원
- 2017년 월 280만 원
- 2018년 월 290만 원

대법원은 기본급, 고정연장근로수당, 고정야간근로수당의 산정 기준이 되는 시간급의 액수가 정해져 있지 않고, 계약서에 기재된 월 단위 기본급(1,260,270원)을 209시간으로 나누어 구한 시급(6,030원)을 기초로 법정수당을 계산하여 월간 급여를 계산하면 2,692,395원인데 이는 계약서에 기재된 금액(2,700,000원) 및 실제 지급된 금액(270만 원)과도 다른 점,⁴²⁾ 임금대장에도 월 정액급여액만 기재된 점 등을 근거로 정액수당제가 아닌 정액급제 포괄임금제라고 판단하였다. 다만 원심이 정액수당제라고 판단하면서도 실제 최저임금법 위반 여부 판단은 정액급제 방식으로 계산하여 포괄임금제의 유형 판단 오류가 파기 사유가 된 것은 아니다.

41) 사실심 판결문상으로는 구체적인 조항의 내용은 확인되지 않는다.

42) 근로계약서 제5조의 세부 항목은 월 270만 원을 배정된 근로시간(209시간, 155시간 × 1.5 등)에 따라 나눈 값을 기재한 것에 불과한 것으로 보인다.

[대법원 2024. 12. 26. 선고 2020다300299 판결]

다. 대법원의 판단

앞서 본 법리에 비추어 이 사건을 살펴본다.

1) 망인의 근로계약서에서 기본급과 법정수당 산정의 기준이 된 시간급의 액수를 정하지 않은 것으로 보이고, 근로계약서에 기본급이 기재되어 있으나 이를 기초로 법정수당을 산정한 후 합산한 월급여액은 실제 지급된 월급여액과 다른 점, 임금대장(을가 제7호증)에도 기본임금과 법정수당을 구별하지 않은 정액의 월급여액이 기재된 점 등을 종합하면, 망인과 피고 F가 기본임금을 별도로 정했다기보다는 기본임금과 법정수당을 모두 포함한 일정한 금액을 월급여액으로 정한 것이라고 봄이 타당하므로 정액급 포괄임금약정을 체결하였다고 보아야 한다. 그런데 원심은 망인과 피고 F가 정액수당 포괄임금약정을 체결하였다고 잘못 판단하면서도 정액수당 포괄임금약정이 아닌 정액급 포괄임금약정에서의 비교대상 임금 산정 방법인 역산 방식을 취하였다. 원심이 망인의 근로계약이 정액수당 포괄임금약정이라고 판단한 것은 판결에 영향을 미친 잘못이 있다고 볼 수 없다.

즉, 대법원은 근로계약서 제5조에 기본급 1,260,270원이 기재되어 있는 하나 계약서의 구체적인 의미와 실제 지급액 등까지 종합적으로 고려하여 정액급제라고 판단한 것으로 볼 수 있다. 앞서 본 바와 같이 정액수당제인지 정액급제인지에 따라 구체적인 결과가 달라질 수 있고, 만일 입법으로 정액급 포괄임금제가 금지된다면 정액수당제인지 정액급제인지의 구분이 더욱 중요해질 것으로 보인다. 따라서 다른 사건에서도 이와 같은 포섭 판단 방법을 참조할 여지가 있다고 보인다.

V. 포괄임금제의 최저임금법 위반 판단 및 차액 계산 방법 (정액급제를 중심으로)

포괄임금제도 최저임금법을 위반하면 안됨은 당연하나, 최근 선고된 대법원 판결들에 따라 변경되어야 할 계산방법이 있고, 정액급 포괄임금제의 경우에는 특별히 유의할 사항이 있다. 우선 포괄임금제가 아닌 일반적인 경우의 최저임금법 사안에 대하여 검토한다.

1. 포괄임금제가 아닌 일반적인 경우 최저임금법 위반 판단 및 차액 계산 방법

(1) 원칙적 방식

판례에 의하면 최저임금법 위반 판단 및 그로 인한 차액 계산 방법은 아래와 같다.

1) 2018. 12. 31. 이전

최저임금법 위반 및 차액 산정에 관하여 법령이 예정한 원칙적인 방식⁴³⁾은 **[①단계]** 비교대상 임금(시급)을 산정하여 법정 최저시급과 비교한 후, **[②단계]** 최저임금 이상의 금액을 지급해야 하는 시간(소정근로시간, 유급주휴시간,⁴⁴⁾ 협의의 연차휴가수당⁴⁵⁾)을 곱하여 최저임금법 위반으로 인한 금액을 계산하는 것이다. 약정 유급휴일이나 약정 유급휴가에

43) 포괄임금제는 월단위로 정해지는 경우가 대부분이므로 비교의 편의상 월급제 사안을 전제로 한다.

44) 대법원 2024. 7. 25. 선고 2021다246545 판결.

45) 연차휴가를 사용하여 근로를 제공하지 않았지만 유급휴가이기 때문에 지급되는 (또는 공제되지 않는) 임금인 협의의 연차휴가수당은 최저임금으로 산정할 임금에 포함된다(대법원 2023다223744, 2023다223751 판결 등). 이와 달리 연차휴가를 사용하지 않아 발생하는 연차휴가 미사용수당은 최저임금으로 산정할 임금에 해당하지 않는다(최저임금법 시행규칙 제2조 제1항 제2호).

대한 임금, 결근일에도 약정에 의하여 지급되는 임금은 법정 최저시급으로 산정할 임금 항목은 아니므로(대법원 2023다223744, 2023다223751 판결 등) 제외된다. [❸단계] 여기서 더 나아가 최저임금법 위반에 따라 증액된 통상임금⁴⁶⁾으로 임금을 산정할 시간(소정근로 외 근로에 대한 임금 및 가산임금 등)을 곱하여 차액을 청구할 수 있다. ❸단계는 최저임금법 위반 영역은 아니고 근로기준법 위반의 영역이다.

■ 원칙적 방법(판례)에 의한 최저임금 미달액 계산 방식

- ❶ 단계: $(\text{법정 최저시급} - \frac{\text{비교대상 임금 월액}}{\text{월 평균 소정근로시간 수}}) \times \text{최저임금법 위반 여부 판단}$
- ❷ 단계: $(\text{법정 최저시급} - \frac{\text{비교대상 임금 월액}}{\text{월 평균 소정근로시간 수}}) \times \text{최저임금으로 임금을 산정해야 하는 시간(소정근로시간, 주휴시간 등)} \times \text{최저임금 미달액 계산}$

2) 2019. 1. 1. 이후

위 계산식에서 “월 평균 소정근로시간 수” 대신 “월 평균 소정근로시간 수 + 유급주휴시간수”⁴⁷⁾를 산입하는 점을 제외하고는 동일하다.⁴⁸⁾

3) 주휴수당⁴⁹⁾ 관련 문제

46) 비교대상 임금이 최저임금으로 증액되면 통상임금을 구성하는 임금 항목 중 비교대상 임금도 증액되기 때문에 결과적으로 통상임금도 그만큼 증액된다.

47) 2018. 12. 31. 개정 시행령은 이를 “최저임금 적용기준 시간 수”라고 하고 있다.

48) 물론 상여금과 복리후생성 임금이 순차로 비교대상 임금에 산입되어 2024년부터는 전액 산입되게 되었으나 이는 위 “비교대상 임금”의 범위 문제여서 본 발제와 직접 관련은 없어 검토를 생략한다.

49) 한편 대법원 2025. 8. 14. 선고 2022다291153 판결은 “근로자와 사용자가 소정근로시간에 관하여만 정하였을 경우, 1주간 소정근로일이 5일에 미달하는 근로

① 2018. 12. 31. 이전의 경우, 판례에 의하면 비교대상 시급을 산정할 때 유급주휴시간은 분모(월 평균 소정근로시간 수)에 포함되지 않지만 주휴수당은 비교대상 임금 항목(분자)에 포함되는 것으로서 최저임금으로 산정할 임금항목에 포함된다(대법원 2024. 7. 25. 선고 2021다246545 판결). 즉, 앞에서 본 ㉒단계에서 최저임금으로 산정하여 차액을 청구할 수 있는 임금 항목이다. 다만 월급제의 경우 별도로 정함이 없는 한 주휴수당은 월급여에 포함되어 있고, 2018. 12. 31.까지는 비교대상 임금 월급여액을 시급으로 전환할 때 분모에 유급주휴시간을 포함하지 않기 때문에 월급여에 포함된 다른 비교대상 임금 항목들이 법정 최저임금에 맞추어 증액되는 과정에서 주휴수당도 같이 증액되는 효과가 있으므로 주휴수당을 별도로 청구하는 경우 중복청구가 될 것이다.⁵⁰⁾ 따라서 최저임금법 위반을 이유로 주휴수당을 별도로 청구하기는 어렵다.⁵¹⁾

② 2019. 1. 1. 이후에는 비교대상 임금 월급여액을 시급으로 전환할 때에 분모에 유급주휴시간 수가 포함되므로 월급여에 포함된 다른 비교대상 임금 항목들이 법정 최저임금에 맞추어 증액되더라도 그 과정에서 주휴수당이 증액되는 효과가 발생하지는 않으므로 별도로 청구할 수 있다.

이와 관련하여 헌법재판소 2019헌마15 결정은 2019. 1. 1.부터 시행되는 시행령 조항(=주 또는 월단위 비교대상 임금 월액을 시급으로 전환할

자에 대하여는 1주간 소정근로일 수를 5일로 보고, 1주간 소정근로시간 수를 5일로 나누는 방법으로 산정하는 것이 타당하다.”고 하였다. 이에 따르면 소정근로일수에 따라 유급주휴시간이 달라지게 된다.

50) 강경미, 주휴수당이 최저임금 지급대상인지 여부, 「대법원 판례해설」, 제141호, 법원도서관, 2024, 499면도 같은 취지이다.

51) 비교대상 임금이 최저임금으로 증액되면서 통상임금도 증액되는 효과가 발생하므로 통상임금 재산정으로 인한 주휴수당 차액분을 별도로 청구할 수 있는 것 인지 의문이 있을 수 있으나, 최저임금법 위반으로 인한 통상임금 증액비율은 비교대상 임금이 최저임금으로 증액되는 비율만큼만 발생하기 때문에 통상임금 증액으로 인한 주휴수당 차액분도 별도로 발생하는 것은 아니다. 이는 2019. 1. 1. 이후도 동일하다. 만일 차액이 별도로 발생한다면 최저임금법 위반으로 통상임금이 증액되면서 주휴수당이 증액되고 또 다시 비교대상 임금(주휴수당)이 증액되는 등 무한 반복 문제가 발생할 것이다.

때에 유급주휴시간을 분모에 포함하도록 한 조항)으로 인하여 비로소 주휴수당도 최저임금으로 산정할 임금이 되는 것처럼 판시하였다.

[헌법재판소 2020. 6. 25. 선고 2019헌마15 결정]

이 사건 시행령조항⁵²⁾은 최저임금의 적용을 위하여 주(週) 단위로 정해진 비교대상 임금을 시간에 대한 임금으로 환산할 때, 1주 동안의 소정근로시간 수와 법정 주휴시간 수를 합산한 시간 수로 해당 임금을 나누도록 하고 있다. 이에 따라, 사용자는 주 단위로 임금이 지급되는 근로자에게 시간급 최저임금액에 ‘소정근로시간 수와 법정 주휴시간 수를 합산한 시간 수’를 곱한 금액 이상을 지급하여야 한다.

헌법재판소 결정의 위 판시는 차액 청구가 가능하다는 점에 있어서는 타당하나 최저임금제도에 대한 올바른 이해⁵³⁾에 기초하였다고 보기는 어렵다. 2019. 1. 1.부터 시행되는 개정 시행령은 주급 또는 월급으로 지

52) 최저임금법 시행령(2018. 12. 31. 대통령령 제29469호로 개정된 것) 제5조 제1항 제2호

53) 한편 헌법재판소 2019헌마15 결정은 이 부분 외에도 최저임금을 오해하고 있는 부분이 있는데 아래 『』부분이다.

『주휴수당은 1주 동안의 소정근로일을 개근한 자에게만 주어진다. 그 결과 이 사건 시행령조항과 같이 ‘최저임금 산정기준 시간 수’에 법정 주휴시간 수를 포함할 경우에는, 근로자가 1주 동안의 소정근로일을 개근한 경우와 그중 1일을 결근한 경우 모두 시간당 비교대상 임금이 동일하게 산출되나, ‘최저임금 산정기준 시간 수’에 법정 주휴시간 수를 포함하지 않을 경우에는 위 두 경우 사이에 시간당 비교대상 임금에 차이가 발생하여, 근로자의 개근 여부에 따라 최저임금법 위반 여부가 달라지는 불합리한 결과가 발생할 가능성이 있다.』

통상임금과 마찬가지로 비교대상 임금 역시 도구 개념이므로 “소정근로를 모두 제공하는 경우”를 전제로 산정해야 하므로 헌법재판소가 예시로 든 위와 같은 경우는 발생할 수가 없다. 만일 헌법재판소 결정의 취지대로라면 1개월 중 29일을 쟁의행위를 하다가 마지막인 30일에 근무한 경우에 29일 동안은 주휴수당은 물론 기본급도 지급되지 않았으므로 30일에 근로한 것에 대한 임금이 최저임금법 위반인지를 판단하기 위한 비교대상 임금을 산정하기가 불가능하다는 것이 되는데, 비교대상 임금은 29일을 실제 근로제공을 했는지와 무관하게 소정근로를 제공할 것을 전제로 산정해야 한다.

급되는 비교대상 임금의 시급 전환에 관한 규정이어서 주급제, 월급제에 적용되는 것인데 주휴수당이 최저임금으로 산정할 임금인지 여부는 시급제, 일급제, 주급제, 월급제 등 임금산정 단위기간에 따라 달라지는 것이 아니다. 위 시행령 개정에 따라 달라지는 것은 비교대상 임금의 월급액(또는 주급액)을 시급을 전환할 때에 분모에 유급주휴시간을 포함해야 한다는 것이고 이는 비교대상 시급이 최저임금으로 증액되는 과정에서 주휴수당 중 최저임금 미달액 부분이 이미 지급되는 효과(즉 중복지급 여부)가 발생하는가 아닌가의 차이에 영향을 줄 뿐이라고 봄이 타당하다. 즉 2018. 12. 31. 이전이든 이후이든 주휴수당은 최저임금을 적용하여 산정할 임금이고, 다만 비교대상 시급 산정 시에 분모에 유급주휴시간이 포함되는지에 따라 별도로 청구할 수 있는지 여부(☞중복청구인지 아닌지)에 차이가 있을 뿐이다.

(2) 실무상 방식

소송실무에서는 위와 같이 다소 복잡한 계산 방법을 사용하지 않고, 아래와 같은 방식으로 계산해 왔다. 이는 앞에서 본 ❶, ❷ 단계를 한꺼번에 계산하는 방식이다.

■ 통상적인 최저임금법 위반 사건에서의 실무상 계산 방식

[2018. 12. 31. 이전]

최저임금 미달액(청구액)

$$= \text{법정 최저시급} \times \text{월 평균 소정근로시간 수} (\text{즉, 주휴시간 미포함}^{54)}) \\ - \text{비교대상 임금에 속하는 월 급여(기지급액)}$$

[2019. 1. 1. 이후]

최저임금 미달액(청구액)

$$= \text{법정 최저시급} \times (\text{월 평균 소정근로시간 수} + \text{유급주휴시간}) \\ - \text{비교대상 임금에 속하는 월 급여(기지급액)}$$

위 방식에 대해서는 당사자들이 이의하는 경우가 거의 없어서 하급심 판결(민사, 형사 모두 포함)뿐 아니라 대법원 판결도 이 방식에 따라 최저임금 미달액을 계산한 원심을 수긍하고 있다. 이러한 계산 방법은 고용노동부가 법정 최저시급과 동시에 월 소정근로시간(주휴시간 포함)이 209시간인 사업장을 기준으로 「법정 최저시급 × 209시간」을 함께 고시해 왔던 것에도 크게 영향을 받은 측면이 있어 보인다.

다만, 대법원 2024. 7. 25. 선고 2023다223744 판결 등이 약정 유급휴일이나 약정 유급휴가에 대한 임금, 결근일에도 약정에 의하여 지급되는 임금은 최저임금으로 산정할 임금이 아니라고 명시적으로 판단한 이후에는 아래와 같이 계산하고 있는 것으로 보인다.⁵⁵⁾ 약정 유급휴일, 약정 유급휴가, 약정에 의한 유급결근일 등과 같이 최저임금으로 임금을 산정할 시간이 아닌 시간을 모두 합하여 ㉠라고 할 경우 다음과 같이 계산된다.

■ 최근의 일반적인 최저임금법 위반 사건에서의 실무상 계산 방식
 = 법정 최저시급 × (월 평균 소정근로시간 수 + 유급주휴시간 - ㉠)
 - 비교대상 임금에 속하는 월 급여(위 ㉠에 대한 임금은 공제한 기 지급액)

그런데 이 방식은 정액급 포괄임금제에서는 그대로 사용할 수 없다. 2항에서 상술한다.

2. 정액급 포괄임금제에서 최저임금법 위반 판단 및 차액 계산 방법

(1) 비교대상 시급 산정

⁵⁴⁾ 다만 고용노동부 행정해석은 주휴시간도 포함한다.

⁵⁵⁾ 대법원 2023다223744 판결의 환송 후 원심인 수원고등법원 2025. 5. 14. 선고 2024나21354, 21361 판결 등의 취지 참조.

1) 2018. 12. 31. 이전

가. 실무상 방법

정액수당제의 경우 기본임금⁵⁶⁾을 기준으로 최저임금법 위반 여부를 판단하게 되므로 앞에서 본 일반적인 경우와 동일하다. 그러나 정액급제의 경우 기본임금이 미리 정해져 있지 않으므로 역산하여 기본임금을 구한 후 최저임금법 위반 여부를 판단해야 하는데 그에 관하여 기존의 판례에 따른 실무가 오류⁵⁷⁾를 범해 왔던 것으로 보인다.

■ 포괄임금제의 재조명, 정재헌, 사법 제15호, 사법발전재단, 2011년 109면

사용자는 미리 근로기준법 제17조에 따라 근로시간, 휴일, 유급휴가, 임금의 구성항목, 계산방법을 명시하여 제공하였을 것이고, 근로시간의 산정이 가능하므로 실제 근로를 제공한 실근로시간이 확정될 것이다. 명시된 근로시간 등을 통해 기본근로시간이 정해지고, 이를 초과한 연장근로시간, 야간에 제공된 근로는 야간근로시간, 보장된 휴일에 제공된 근로는 휴일근로시간으로 계산된다. 기본근로시간과 법정 제수당의 지급대상인 근로시간을 나누고 근로기준법에서 정한 법정 제수당의 최소한도액을 적용하게 되면 지급된 총임금액 중 기본근로시간에 대한 대가와 법정 제수당에 해당하는 액수를 역산할 수 있다(각주 84번). 이 금액에 대하여 최저임금법에서 정한 최저임금액을 위반하지 않았는지, 단체협약이나 취업규칙에서 정한 근로조건에 비추어 근로자에게 불이익하지 않는지 살펴 근로관계법 위반 여부를 판단하고 유효성을 평가하면 될 것이다.

(각주 84번) 예를 들어 다른 조건은 문제되지 않는다는 가정 아래, 기본근로시간 1개월에 280시간, 총액임금 100만 원으로 정한(명시한) 업무에 대하여 실제 총 근로시간은 1개월에 360시간이었다면 연장근로시간(야간, 휴일근무는 없다고 가정한다)은 80시간이다. 연장근로수

⁵⁶⁾ 기본임금 외에 비교대상 임금에 포함되는 다른 수당이 있을 수 있으나, 이하에서는 별도로 언급하지 않는 한 기본임금만 있는 것으로 전제하고 논의한다.

⁵⁷⁾ 다만 비교대상 시급 산정에서의 오류가 근로자에게 불리하지는 않았다.

당은 최저한도인 1.5배로 계산할 때 총액임금 100만 원 = $(280 \times \text{기본임금}) + \{(80 \times \text{기본임금} \times 1.5)\}$ 이 된다. 이 경우 기본임금은 시간당 2,500원으로 역산된다.

위 문헌에서 소개한 정액급 포괄임금제에서의 기본임금 계산방법은 지급받은 정액급여 총액(100만 원)을 기본근무시간(280시간)에 가산율을 반영한 연장근로시간($80\text{시간} \times 1.5$)으로 나눈다는 것이어서 아래에서 소개하는 김현수의 방식과 동일하고 대다수의 하급심 판결들이 따르고 있는 계산 방식이다. 보다 최근의 자료인 김현수의 저서를 통해서 위 계산 방식이 맞는 계산 방식인지 검토한다.

■ 최저임금법, 김현수, 법원사, 2018년, 151면

2. 포괄임금제에 대한 시간급 임금

최저임금위원회의 산출 방법을 보면, 소정 근로시간이 1일 8시간, 1주 40시간이고 주 5일을 근무하는 근로자가 매월 시간외 근로를 총 6시간 하는 경우에, 월 소정근로시간 수는 209시간이고 연장근로시간을 임금을 기준으로 시간을 환산하면 연장근로시간당 50%의 가산임금을 지급해야 하므로 6시간의 50%인 3시간을 더하면 연장근로에 대한 임금에 상당하는 9시간($= 6\text{시간} \times 1.5$)이 된다. 따라서 월 포괄임금을 200만 원이라고 보면 시간급 임금은 $200\text{만 원} \div 218 (= 209\text{시간} + 9\text{시간}) = 9,174\text{원}$ 이 된다. 대법원 판례에 따르면, 월 소정근로시간 수가 174시간이므로, 시간급 임금은 $200\text{만 원} \div 183\text{시간} (= 174\text{시간} + 9\text{시간}) = 10,929\text{원}$ 이 된다.

위 김현수의 저서에서 “대법원 판례에 따르면”이라고 하면서 소개한 방식은 비교대상 임금인 분자(200만 원)에 포함된 주휴수당을 「소정근로시간 수(174시간)」가 아니라 「소정근로시간 수(174시간) + 가산율이 반영된 연장근로시간 수(9시간)」로 나누는 것이어서 직관적으로 보더라도 오류가 있다.

나. 정확한 방법

정확한 계산 방법은 앞에서 본 일반적인 경우의 원칙적 방법을 적용하는 것이다. 다만 정액급제의 경우 기본임금이 특정되어 있지 않으므로 역산하여 기본임금을 구하는 과정은 별도로 거쳐야 한다. 역산할 때에 법령이나 당사자의 약정 등 다른 특별한 근거가 없는 한 동일한 근로를 제공한 시간에 대한 시급은 동일⁵⁸⁾하고, 정액급 포괄임금제가 성립하였으므로 근로기준법상의 법정수당은 적법하게 지급되었음도 전제한다.

이러한 전제하에 역산하면 위 예시의 근로자가 받은 월 200만 원의 포괄임금은 ㉠ 소정근로시간(174시간⁵⁹⁾)에 대한 임금, ㉡ 유급주휴시간(35시간⁶⁰⁾)에 대한 임금, ㉢ 6시간의 연장근로에 대한 수당(=50% 가산율을 반영하면 9시간에 대한 임금) 즉, 총 218시간(=174 + 35 + 9)에 대한 임금으로 구성되어 있다. 아래 계산에 의하면 200만 원에 대한 기본임금의 시급은 9,174원(=200만 원 ÷ 218시간)이고 위 문헌 및 행정해석에 따른 계산 결과 (9,174원)와 일치한다. 기본급만 존재하는 경우이므로 9,174원이 행정해석에 따른 비교대상 임금의 시급이자 동시에 통상시급이 된다.⁶¹⁾

■ 200만 원의 구성(=㉠, ㉡, ㉢에 대한 임금)

㉠에 대한 임금 $\approx 1,596,330\text{원} \left(\approx 2,000,000\text{원} \times \frac{174}{218} \right)$

58) 대법원 2020. 1. 22. 선고 2015다73067 전원합의체 판결 「특별한 사정이 없는 한, 근로제공시간에 대한 급여는 같은 액수로 정해져 있다고 보는 것이 통상적인 임금 계산의 원리에 부합하고 가장 공평하며 합리적이다. ‘동일한 근로’를 제공한 시간에 대해 매 시간당 가치 평가는 같다고 보는 것이 원칙이다. 법령이나 당사자의 약정 등과 같은 특별한 근거 없이 이를 달리 보는 것은 근로의 가치에 대한 자의적 평가에 해당한다」 참조.

59) 정확히는 173.8시간[$\approx 40\text{시간} \times 4.345\text{주}(\approx 1\text{개월의 평균 주수})$]임.

60) 정확히는 34.76시간[$\approx 8\text{시간} \times 4.345\text{주}(\approx 1\text{개월의 평균 주수})$]임.

61) 판례에 의하면 위 근로자는 통상시급은 9,174원이지만 비교대상 시급은 11,020원이 된다.

$$\text{㉑에 대한 임금} \approx 321,101\text{원} \left(\approx 2,000,000\text{원} \times \frac{35}{218} \right)$$

$$\text{㉒에 대한 임금} \approx 82,569\text{원} \left(\approx 2,000,000\text{원} \times \frac{9}{218} \right)$$

그러나 판례에 의하면 2018. 12. 31.까지는 ㉑, ㉒는 분자(비교대상 임금)에 포함되고, 분모(소정근로시간 수)에는 174시간(㉑)만 반영되어야 한다. 따라서 비교대상 임금(분자)에 포함될 임금액수는 200만 원이 아니라 1,917,431원 (=1,596,330원 + 321,101원)이고, 소정근로시간 수(분모)에 포함될 시간은 174시간(㉑)이므로, 비교대상 시급은 11,020원(= $\frac{1,917,431\text{원}}{174\text{시간}}$)이 된다. 위 문헌의 10,929원은 잘못 계산한 것으로 보인다. 2018. 12. 31.까지는 판례에 의하면 분자(비교대상 임금)와 분모(소정근로시간 수)의 구성항목이 불일치하기 때문에 분자와 분모 모두에 주휴수당 및 유급주휴시간을 포함하는 방법으로 계산하면 오류가 발생한다. 분자(200만 원)에 포함된 주휴수당(㉑)을 소정근로시간 수(174시간)가 아니라 연장근로 가산율까지 반영된 시간(183시간=174시간 + 9시간)으로 나눈 부분에 위 문헌의 오류가 있는 것이고 그 오류 분은 91원⁶²⁾인데, 정확하게 계산한 값(=11,020원)과 위 문헌의 오류(=10,929원)의 차이와 일치한다. 연장근로시간 수가 많을수록 위 오류는 커지게 되어 있다. 이러한 오류를 대다수의 하급심이 반복해 온 것으로 보이고, 일부는 상고 이유 등으로 정확히 제기되지 않아서 대법원 판결에서도 명확하게 시정되지 않았던 것으로 보인다.⁶³⁾ 다만 최근 들어 동일한 오류를 범한 원심 판결을 대법원 2023. 11. 2. 선고 2018도965 판결이 파기하기도 하였고,

62) 주휴수당(321,101원)을 소정근로시간(174시간)이 아니라 (연장근로에 대한 가산율까지 반영된 시간(183시간)으로 나눔으로 인하여 발생하는 차이 91원 = $\frac{321,101\text{원}}{174\text{시간}} - \frac{321,101\text{원}}{183\text{시간}} \approx 1,845\text{원} - 1,755\text{원} \approx 91\text{원} (90.75777\dots)$

63) 대법원 2011도12114 판결, 대법원 2014도12265 판결, 대법원 2014도8873 판결, 대법원 2014다44673 판결 등

대법원 2024. 12. 26. 선고 2020다300299 판결에서 아래와 같은 계산식으로 명확히 하기도 하였다.⁶⁴⁾

■ 2018. 12. 31. 이전 정액급 포괄임금제에서 비교대상 시급 역산 방법
(대법원 2020다300299 판결)

$$\text{비교대상 시급} = \frac{\text{월급액} \times \frac{\text{월 소정근로시간} + \text{월 유급 주휴시간}}{\text{월 소정근로시간} + \text{월 유급 주휴시간} + \text{가산율을 반영한 월 연장·야간·휴일근로시간}}}{\text{월 소정근로시간}}$$

2) 2019. 1. 1. 이후

앞에서 본 2018. 12. 31.까지의 정액급 포괄임금제에서 비교대상 시급 산정 시의 오류는 판례가 노동부 입장과 달리 비교대상 임금의 월 급여액을 시급으로 전환할 때에 유급주휴시간을 분모에 포함하지 않으면서도 계산은 동일⁶⁵⁾하게 하여 발생한 오류이다. 그렇다면 2019. 1. 1. 이후에는 시행령 개정으로 유급주휴시간이 분모에 포함되므로 아무 문제가 없는 것일까? 근로기준법 주해는 아래와 같이 서술하고 있다.

■ 근로기준법 주해(2025년, 제2판 수정증보판) 33면

③ (상시 5인 이상 사업장) 월 기본급 2,500,000원, 약정 근로시간 1주 44시간, 주휴일 부여, 약정 근로시간을 기준으로 지급된 기본급에 연장근로수당을 포함하기로 한 경우
시간급 비교대상 임금 10,654원=2,500,000원÷[(1주 소정근로시간 40시간+가산율이 반영된 1주 연장근로시간 6시간+1주 주휴시간 8시간)×(365일÷7일)÷12개월]

⁶⁴⁾ 위 2건의 대법원 판결 모두 기본임금과 주휴수당 외에 비교대상 임금에 포함되는 다른 수당이 없는 경우를 전제로 한 판결이다.

⁶⁵⁾ 노동부 방식도 다소 편의적인 방식이나 분자(비교대상 임금)와 분모(최저임금 적용 기준 시간 수)의 구성항목이 동일하여 적어도 비교대상 시급 산정 단계에서 직접적인 오류가 발생하지는 않는다.

근로기준법 주해의 위 설명은 기본급만 존재하여 「통상시급 = 비교대상 임금의 시급」⁶⁶⁾임을 전제로 한 것이다. 이것이 전제되었기 때문에 정액급 포괄임금의 월 급여액에 포함된 기본임금과 연장근로수당 등을 모두 동일하게 235시간⁶⁷⁾으로 나눈 것이다. 그러나 격월로 지급되는 정근수당과 같이 통상임금에는 포함되나 비교대상 임금에는 포함되지 않는 수당이 있는 경우에는 「통상시급 > 비교대상 시급」이므로 아래와 같이 다소 복잡한 상황이 발생할 수 있다(비교대상 시급이 다액인 반대의 경우도 있을 수 있다).⁶⁸⁾

■ 통상시급과 비교대상 시급이 다른데 정액급 포괄임금을 역산할 경우 발생하는 문제

「월 포괄임금 총액: A, 기본급(시급): x, 소정근로시간: a, 연장근로시간: b, 유급주휴시간: c」인 경우를 상정하고, 통상임금에 포함되나 비교대상 임금에는 포함되지 않는 다른 임금 항목(ex. 격월로 지급되는 정근수당)을 y라고 함. 위 a, b, c는 월(月)평균을 의미함. y가 없다면 $A = (a + 1.5b + c) x$ 가 됨. 그러나 y가 있으므로 「통상시급(z) = 기본시급(x) + 시급으로 전환한 y」가 되고, $A = ax + (1.5b + c)z$ 가 됨. 즉, A중 기본시급(x)으로 지급된 금액과 통상시급(z)으로 지급된 금액을 구분한 후, a, c에 대하여 지급된 임금을 역산해야 함. 물론 역산하는 방법은 법률에서 정한 것이 아니고 당사자 의사 해석의 문제이므로

66) 2019. 1. 1. 이후에 비교대상 시급 산정 시에는 분자에 주휴수당이 포함되고 분모에도 유급주휴시간이 포함된다. 한편 달리 정함이 없는 한 월급여에는 주휴수당이 포함되어 있다는 것이 대법원 판례이고, 통상시급 산정 시에 분자에 주휴수당을 포함(즉, 주휴수당이 포함된 월급여를 그대로 산입)하고, 분모에도 유급주휴시간을 포함하는 방식으로 통상시급을 산정하는 것이 가능(대법원 90다카 14758 판결 등)하므로 기본급만 존재하는 경우 비교대상 시급과 통상시급은 동일하다.

67) $234.64 \dots$ 시간 = 1주 소정근로시간 40시간 + 가산율이 반영된 1주 연장근로시간 6시간 + 1주 주휴시간 8시간 $\times (365일 \div 7일) \div 12$ 개월

68) 이는 2018. 12. 31. 이전에도 다르지 않았다. 2018. 12. 31. 이전에는 비교대상 임금에 포함되는 임금 항목이 적어서 통상임금에 포함되는 임금 항목과의 차이가 더 컸기 때문에 발생 가능성이 더 큰 쟁점이었다.

y수당이 있음에도 불구하고 모든 근로시간에 대하여 동일한 임금이 지급되었다고 전제하고 $A = (a + 1.5b + c) \times x$ 를 전제로 역산할 수도 있음. 그러나 그 경우에는 통상시급을 과소하게 산정하여 연장근로수당을 지급한 것이 되어 차액 청구가 가능해 지는데, 이는 일반적인 정액급 포괄임금제에서 법정수당이 적법하게 지급되었음을 전제하는 상황과 맞지 않음

(2) 차액 계산

1) 실무상 방법

여러 하급심 판결들은 일반적인 임금체계에서의 실무상 차액 계산과 유사한 방법으로 정액급 포괄임금제에서 최저임금법 위반으로 인한 차액을 계산하는 오류를 범하고 있다. 즉, 「법정 최저시급 $\times$ 주휴시간 제외한 총 임금시간(가산을 반영) - 월 포괄임금 총액(기지급액)」의 방식으로 차액을 계산한 판결들이 여럿 존재한다. 그리고 이러한 오류가 있는 계산 방식을 정액수당제 포괄임금제에서도 그대로 사용하는 판결도 적지 않다. 이러한 계산 방식들은 통상임금으로 산정할 각종 가산임금을 모두 최저임금으로 계산한 것이어서 그 자체로 오류가 발생한다.⁶⁹⁾

최저임금으로 산정할 임금과 통상임금으로 산정할 임금을 명시적으로 구분한 대법원 2017. 12. 28. 선고 2014다49074 판결 선고 이전⁷⁰⁾은 물론이고 그 이후에도 판례 실무가 크게 달라지지 않은 것으로 보인다.⁷¹⁾ 2019. 1. 1. 전후하여 유급주휴시간을 포함하였는지 여부의 차이만 있을 뿐이다.

69) 정액급제이든 정액수당제이든 마찬가지이다.

70) 대법원 2014도12265 판결, 대법원 2014도8873 판결, 대법원 2014다44673 판결의 원심도 마찬가지로 계산된 사안으로 보이고, 대법원에서 이 부분은 별도로 판단 대상이 되지 않은 것으로 보인다.

71) 아래의 판결들은 모두 대법원 2017. 12. 28. 선고 2014다49074 판결 이후의 판결들이다.

[대법원 2017. 12. 28. 선고 2014다49074 판결]

이와 같이 최저임금이나 최저임금의 적용을 위한 비교대상 임금은 통상임금과는 그 기능과 산정 방법이 다른 별개의 개념이므로, 사용자가 최저임금의 적용을 받는 근로자에게 최저임금액 이상의 임금을 지급하여야 한다고 하여 곧바로 통상임금 자체가 최저임금액을 그 최하한으로 한다고 볼 수 없다. 다만 최저임금의 적용을 받는 근로자에게 있어서 비교대상 임금 총액이 최저임금액보다 적은 경우에는 비교대상 임금 총액이 최저임금액으로 증액되어야 하므로, 이에 따라 비교대상 임금이 산입된 개개의 임금도 증액되고 그 증액된 개개의 임금 중 통상임금에 해당하는 임금들을 기준으로 통상임금이 새롭게 산정될 수는 있을 것이다.

서울북부지방법원 2024. 7. 9. 선고 2022나34914 판결,⁷²⁾ 서울남부지방법원 2024. 4. 18. 선고 2023나64841 판결,⁷³⁾ 부산지방법원 2019. 12. 18. 선고 2019나49427 판결,⁷⁴⁾ 서울중앙지법 2019. 2. 14. 선고 서울중앙지법 2018나57492 판결⁷⁵⁾ 등 다수의 하급심 판결들이 최저임금법 위반에 따라 원고들이 청구할 수 있는 금액을 「법정 최저시급 × 정액급 또는 정액수당제 포괄임금 산정의 기초가 된 모든 근로시간(가산율도 반영)」으로 계산함으로써 통상임금으로 산정할 가산임금도 모두 최저임금을 기준으로 산정한 것으로 보인다. 앞에서 본 대법원 2018도965 판결의 원심도 연차휴가미사용수당과 소정근로를 초과하는 약정 연장근로시간을, 대법원 2020다300299 판결의 원심도 소정근로를 초과하는 약정 연장근로시간을 각각 최저임금을 기준으로 산정하였다.⁷⁶⁾

72) 정액수당제, 대법원 2024다269235 심리불속행 판결로 확정되었다.

73) 정액급제, 대법원 2024다243745 심리불속행 판결로 확정되었다.

74) 정액수당제, 상고제기되지 않고 확정되었다.

75) 정액급제, 상고제기되지 않고 확정되었다.

76) 대법원 2020다300299 판결 사안은 결과적으로 최저임금법 위반 사안이 아니라고 판단되어 환송 후 원심(서울고등법원 2024나2064858 판결, 미상고 확정)은 최저임금법 위반에 관해서는 구체적인 금액을 산정하지 않았고, 대법원 2018도965 판결의 환송 후 원심(서울남부지방법원 2023노1703 판결, 미상고 확정)은

2) 정확한 방법

차액 청구는 최저임금으로 산정할 수당(㉠)과 최저임금법 위반에 따라 증액되는 통상임금으로 산정할 수당(㉡)으로 구분된다. 전자(㉠)는 최저임금법 위반에 관한 것이고, 후자(㉡)는 근로기준법 위반에 관한 것이다. 실제 근로를 제공한 소정근로시간에 대한 임금은 법정 최저임금 이상으로 산정해야 할 임금이나, 연장·야간·휴일근로수당은 가산임금(50%)뿐 아니라 (소정근로가 아닌) 연장·야간⁷⁷⁾·휴일근로 그 자체에 대한 임금(100%)도 최저임금이 아닌 증액된 통상임금으로 산정해야 한다(대법원 2014다49074 판결, 대법원 2018도965 판결의 취지, 대법원 2020다300299 판결의 취지⁷⁸⁾ 등⁷⁹⁾). 또한 약정 유급휴일, 약정 유급휴가, 결근 일에도 약정에 의하여 지급되는 임금은 법정 최저임금 이상으로 산정할 임금 항목은 아니지만 협의의 연차휴가수당은 법정 최저임금 이상으로 산정할 임금에 해당한다(대법원 2023다223744, 2023다223751 판결 등).

정확한 방법으로 차액을 산정한 것으로 보인다.

- 77) 야간근로수당의 경우 소정근로 그 자체가 야간근로인 경우에는 소정근로에 대한 임금(100%)은 법정 최저임금을 기준으로, 가산임금(50%)는 증액된 통상임금을 기초로 산정해야 한다.
- 78) 대법원 2018도965 판결과 대법원 2020다300299 판결은 정액급 포괄임금제에서 비교대상 시급 산정 시에 소정근로를 초과한 약정 연장근로에 대한 임금(예를 들어 2시간의 연장근로 그 자체에 대한 임금 100%)을 비교대상 임금에 포함하면 안 된다고 판시한 것이나, 비교대상 임금에 포함되면 최저임금으로 산정할 임금에도 해당하므로 결과적으로 연장근로 그 자체에 대한 임금(100%)도 최저임금으로 산정할 임금이 아니라는 판단도 한 것으로 볼 수 있다.
- 79) 행정해석도 마찬가지이다. 행정해석은 「최저임금 > 통상임금」 사안에서 1일 10시간의 근로 중 2시간의 연장근로에 대하여 ① 2시간의 연장근로 자체에 대한 임금(100%)은 최저임금 이상의 금액을 지급하고(즉, 통상임금으로 지급하는 것만으로는 부족함), ② 2시간의 연장근로에 대한 가산임금(50%)은 최저임금에 미달하는 통상임금으로 지급해도 된다고 해석하였었다(2011. 10. 14. 근로개선정책과-3589). 그러나 대법원 2017. 12. 28. 선고 20014다49074 판결에 따라 입장을 변경하여, 2시간의 연장근로 자체에 대한 임금과 가산임금 모두(즉, 150%) 최저임금에 미달하는 증액된 통상임금으로 지급해도 된다고 입장을 변경하였다(2019. 12. 11. 근로기준정책과-6245).

3. 소결

결론적으로 정액급 포괄임금제의 경우 일반적인 최저임금법 위반 사건에서와 동일·유사하게 간이한 실무상 방식을 사용하면 2018. 12. 31. 이전은 물론이고 2019. 1. 1. 이후에도 오류를 범할 가능성이 높아진다고 볼 수 있다. 앞에서 살펴 본 대법원 2018도965 판결에 대하여 정현주(월간 노동리뷰, 한국노동연구원, 2024. 2.)는 위 대법원 판결이 하급심의 오류를 정확하게 지적하면서 정액급 포괄임금제에서 최저임금법 위반 계산 방법을 정확하게 제시하였다고 평가하면서도 ‘근로시간 산정이 가능함에도 고정된 월급 속에 시간외수당이 녹아 들어간 정액급제 포괄임금약정의 유효성을 인정하는 것은 근로시간 관리를 포기한 사용자의 이익을 대변할 뿐이고, 법원이 아무런 정교한 계산방식을 제시한다고 하더라도 계약 당사자조차 임금항목과 계산방법을 알지 못하는 정액급제 포괄임금약정을 어떤 해석으로 계속 유지할 수 있을지 의문이다.’라고 평가하고 있는바, 매우 공감이 가는 평가라고 생각된다.

■ 정현주, 정액급 포괄임금약정을 체결한 경우에 최저임금 미달 여부 판단 (월간 노동리뷰, 2024. 2.)

...(생략)...대법원의 판시와 ③~⑨의 계산 과정을 거쳐야만 본인이 제공한 근로에 대한 대가인 임금이 최저임금에 미달하지는 않는지, 시간 외근로에 대한 대가를 제대로 셈하여 받고 있는지를 알 수 있다. 법원마저 헛갈리는 계산법을 개별 근로자가 익혀 권리를 보장받기 어렵다. 사용자가 제공한 오렌지 주스의 농도를 근로자더러 계산해 내라는 것과 진배없다. 근로시간 산정이 어렵거나 불가능한 경우에 포괄임금 약정을 인정할지 말지의 문제는 별론으로 하자. 근로시간 계산이 가능함에도 이렇게 정액급제 포괄임금약정을 체결한 것은 어떤 측면에서 보더라도 “계산의 편의와 근로자의 의욕을 고취”한다고 볼 수 없다. 근로시간 산정이 가능함에도 고정된 월급 속에 시간외수당이 녹아 들어간 정액급제 포괄임금약정의 유효성을 인정하는 것은 근로시간 관리를 포기한 사용자의 이익을 대변할 뿐이다.

최소한 소정근로에 대한 대가로서 지급되는 기본급은 구분하여 명시토록 해야만 근로자 본인이 최저임금 이상을 받는지 정도라도 확인할 수 있다. 사용자가 최저임금을 위반하는 임금수준을 결정하는 것을 예방할 수 있다. 근로기준법 제48조에 따라 2021. 11. 19.부터 사용자에게 임금을 지급할 때마다 임금의 구성항목별 금액과 계산방법 등이 명시된 임금명세서 교부 의무를 부과하는 이유가 “사용자와 근로자가 임금에 대한 정보를 정확히 주고받고, 임금체불이 발생할 경우 사용자와 근로자 간 액수 등에 대한 다툼의 소지를 줄이는 것”에 있다는 점을 상기해 보면, 법원이 아무런 정교한 계산방식을 제시한다고 하더라도 계약 당사자조차 임금항목과 계산방법을 알지 못하는 정액급제 포괄임금약정을 어떤 해석으로 계속 유지할 수 있을지 의문이다.

VI. 정액급 포괄임금제가 성립하지 않거나 무효인 경우 이미 지급된 금원의 성질

정액급 포괄임금제가 성립하지 않거나 무효인 경우 근로자에게 이미 지급된 정액급 포괄임금 명목의 금원(이하 ‘정액급여’라고 한다)을 기본급(통상임금 등)으로 보아 근로자가 이를 계속 보유하면서 동시에 이를 기초로 다시 법정수당을 산정하여 청구할 수 있는지, 아니면 이미 지급된 정액급여는 유효한 근거 없이 지급된 것이므로 정액급여 중 법정수당에 상당하는 금액을 부당이득으로 보아 반환대상으로 삼고, 다시 적절한 방법으로 기본급을 산정하여 법정수당을 재산정하여 청구해야 하는지가 문제될 수 있다.

참조할 판결들을 우선 검토한 후 위 쟁점에 대하여 검토한다.

1. 참조 판결들

(1) 퇴직금 분할 약정에 기하여 지급된 퇴직금 명목의 금원의 성질

이른바 퇴직금 분할 약정에 기하여 지급된 퇴직금 명목 금원이 퇴직금 중간정산 또는 퇴직금 지급으로서의 효력이 없는 경우 그 금원의 성질이 부당이득인지 임금인지에 대하여 여러 논쟁이 있었는데, 대법원 2010. 5. 20. 선고 2007다90760 전원합의체 판결은 다음과 같은 이유로 부당이득⁸⁰⁾이라고 판단하였다.

[대법원 2010. 5. 20. 선고 2007다90760 전원합의체 판결]

한편, 법 제18조에서 규정하고 있는 임금은 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 지급하는 일체의 금원으로서, 근로자에게 계속적·정기적으로 지급하고 그 지급에 관하여 사용자가 단체협약, 취업규칙, 급여규정, 근로계약, 노동관행 등에 따라 지급의무를 부담하는 것을 의미한다(대법원 1999. 9. 3. 선고 98다34393 판결, 대법원 2006. 12. 8. 선고 2006다48229 판결 등 참조). 그런데 근로관계의 계속 중에 퇴직금 분할 약정에 의하여 월급이나 일당과는 별도로 실질적으로 퇴직금을 미리 지급하기로 한 경우 이는 어디까지나 위 약정이 유효함을 전제로 한 것인바, 그것이 위와 같은 이유로 퇴직금 지급으로서의 효력이 없다면, 사용자는 본래 퇴직금 명목에 해당하는 금원을 지급할 의무가 있었던 것이 아니므로, 위 약정에 의하여 이미 지급한 퇴직금 명목의 금원은 법 제18조 소정의 ‘근로의 대가로 지급하는 임금’에 해당한다고 할 수 없다.

이처럼 사용자가 근로자에게 퇴직금 명목의 금원을 실질적으로 지급하였음에도 불구하고 정작 퇴직금 지급으로서의 효력이 인정되지 아니할 뿐만 아니라 법 제18조 소정의 임금 지급으로서의 효력도 인정되지 않는다면, 사용자는 법률상 원인 없이 근로자에게 퇴직금 명목의 금원을 지급함으로써 위 금원 상당의 손해를 입은 반면 근로자는 같은 금액 상당의 이익을 얻은 셈이 되므로, 근로자는 수령한 퇴직금 명목의 금원을 부당이득으로 사용자에게 반환하여야 한다고 보는 것이 공평의 견지에서 합당하다.

80) 이에 대하여 임금에 해당한다는 김영란, 김능환 대법관의 별개 및 반대 의견이 있었다.

그러나 대법원은 곧이어 다음과 같은 법리를 실시하여 실질적인 퇴직금 분할 약정이 존재하는 경우에만 부당이득이라고 볼 수 있고, 그렇지 않은 경우에는 이를 임금이라고 볼 수 있다고 하였다.⁸¹⁾

[대법원 2010. 5. 27. 선고 2008다9150 판결]

이처럼 ...(생략)... 공평의 견지에서 합당하다(대법원 2010. 5. 20. 선고 2007다90760 전원합의체 판결 참조).

다만 퇴직금 제도를 강행법규로 규정한 입법취지를 감안할 때, 위와 같은 법리는 사용자와 근로자 사이에 실질적인 퇴직금 분할 약정이 존재함을 전제로 하여 비로소 적용할 것인바, 사용자와 근로자가 체결한 당해 약정이 그 실질은 임금을 정한 것에 불과함에도 불구하고 사용자가 퇴직금의 지급을 면탈하기 위하여 퇴직금 분할 약정의 형식만을 취한 것인 경우에는 위와 같은 법리를 적용할 수 없다고 할 것이다. 즉, 사용자와 근로자 사이에 월급이나 일당 등에 퇴직금을 포함시키고 퇴직 시 별도의 퇴직금을 지급하지 않는다는 취지의 합의가 존재할 뿐만 아니라, 임금과 구별되는 퇴직금 명목 금원의 액수가 특정되고, 위 퇴직금 명목 금원을 제외한 임금의 액수 등을 고려할 때 퇴직금 분할 약정을 포함하는 근로계약의 내용이 종전의 근로계약이나 근로기준법 등에 비추어 근로자에게 불이익하지 아니하여야 하는 등, 사용자와 근로자가 임금과 구별하여 추가로 퇴직금 명목으로 일정한 금원을 실질적으로 지급할 것을 약정한 경우에 한하여 위와 같은 법리가 적용된다 할 것이다.

즉, 판례에 의하면 임금과 구별하여 추가로 퇴직금 명목으로 일정한

81) 대법원 2008다9150 판결은 위와 같은 법리를 실시하면서도, 해당 사안에서는 부당이득이라는 취지로 원심을 파기하였고, 환송 후 원심에서 조정으로 종결되었다. 그러나 대법원 2012. 10. 11. 선고 2010다95147 판결, 대법원 2012. 12. 13. 선고 2012다77006 판결, 대법원 2020. 8. 29. 선고 2017다290613 판결, 대법원 2022. 3. 17. 선고 2018다244877 판결 등은 위와 같은 법리를 실시하면서 해당 사안에서도 실질적인 퇴직금 분할 약정이 존재한다고 보기 어렵고, 기지급된 퇴직금 명목의 금원은 임금에 해당할 여지가 크다는 취지로 판단하였다.

금원을 실질적으로 지급할 것을 약정한 경우에 한하여 공평의 원칙상 이미 지급된 퇴직금 명목의 금원을 부당이득이라고 볼 수 있고, 그렇지 않고 그 실질이 임금을 정한 것에 불과함에도 퇴직금 지급을 면탈하기 위하여 퇴직금 분할 약정의 형식만을 갖춘 경우에는 임금이라고 보아야 한다.

(2) 기준근로시간을 초과하는 약정 근로시간에 대한 월 고정수당을 시간급 통상임금으로 환산하는 방법

기준근로시간을 초과하는 약정 근로시간에 대한 임금인 월 고정수당을 시간급 통상임금으로 환산하는 방법에 관하여 대법원 2015다73067 전원합의체 판결은 아래와 같이 판시하였다.

[대법원 2020. 1. 22. 선고 2015다73067 전원합의체 판결]

근로기준법이 정한 기준근로시간을 초과하는 약정 근로시간에 대한 임금으로서 월급 형태로 지급되는 고정수당을 시간급 통상임금으로 환산하는 경우, 시간급 통상임금 산정의 기준이 되는 총근로시간 수에 포함되는 약정 근로시간 수를 산정할 때는 특별한 정함이 없는 한 근로자가 실제로 근로를 제공하기로 약정한 시간 수 자체를 합산하여야 하는 것이지, 가산수당 산정을 위한 ‘가산율’을 고려한 연장근로시간 수와 야간근로시간 수를 합산할 것은 아니다.

위 전원합의체 판결 사안은 버스 기사들이 근속수당 등이 통상임금에 추가되어야 함을 전제로 통상임금을 재산정하여 법정수당 차액을 청구한 사안이다. 사용자인 피고는 포괄임금약정이 성립되었음을 주장했으나 1심부터 대법원까지 일관되게 포괄임금 합의의 성립 자체를 부정하였다.⁸²⁾ 전원합의체 판단의 쟁점은 기준근로시간을 초과하는 약정 근로시간에 대한 임금인 월 고정수당을 시간급 통상임금으로 환산할 때에 분

82) 피고는 정액급 포괄임금제 성립을 주장했던 것으로 보인다.

모에 가산율을 반영할지 여부이다. 대법원은 특별한 정함이 없는 한 가산율을 고려하지 않고 실제 근로를 제공하기로 약정한 시간 수만을 반영해야 한다고 판단하였다. 노사 당사자의 의사를 확인할 수 있는 사정이 없는 한(=특별한 정함이 없는 한) 기준근로시간을 초과하는 약정 근로시간에 대하여 지급된 임금은 약정한 시간 수 자체에 대한 임금이지 거기에 가산율까지 고려한 근로시간에 대한 임금이라고 볼 수 없다는 것으로 이해된다.

2. 검토

앞에서 이미 검토한 바와 같이 포괄임금제에 관한 약정이 성립하였는지는 근로시간, 근로형태와 업무의 성질, 임금 산정의 단위, 단체협약과 취업규칙의 내용, 동종 사업장의 실태 등 여러 사정을 전체적·종합적으로 고려하여 구체적으로 판단하여야 하며, 비록 개별 사안에서 근로형태나 업무의 성격상 연장·야간·휴일근로가 당연히 예상된다고 하더라도 기본급과는 별도로 연장·야간·휴일근로수당 등을 세부항목으로 명백히 나누어 지급하도록 단체협약이나 취업규칙, 급여규정 등에 정하고 있는 경우는 포괄임금제에 해당하지 아니한다(대법원 2008다57852 판결). 또한 단체협약이나 취업규칙 및 근로계약서에 포괄임금이라는 취지를 명시하지 않았음에도 묵시적 합의에 의한 포괄임금약정이 성립하였다고 인정하기 위해서는, 근로형태의 특수성으로 인하여 실제 근로시간을 정확하게 산정하는 것이 곤란하거나 일정한 연장·야간·휴일근로가 예상되는 경우 등 실질적인 필요성이 인정될 뿐 아니라, 근로시간, 정하여진 임금의 형태나 수준 등 제반 사정에 비추어 사용자와 근로자 사이에 정액의 월급여액이나 일당임금 외에 추가로 어떠한 수당도 지급하지 않기로 하거나 특정한 수당을 지급하지 않기로 하는 합의가 있었다고 객관적으로 인정되는 경우여야 한다(대법원 2016도1060 판결).

(1) 정액급 포괄임금제의 성립이 부정되는 경우 기지급된 정액급여의 성질

1) 부당이득으로 볼 수는 없음

위에서 본 포괄임금제 성립에 관한 법리에 의하면 정액급 포괄임금제의 성립 자체가 부정되는 경우는 ① 단체협약, 취업규칙 등에서 기본급과 별도로 연장·야간·휴일근로수당 등을 구분하여 지급하도록 정하고 있고, (묵시적 포괄임금약정의 경우) ② 실제 근로시간을 정확하게 산정하는 것이 곤란하지도 않는 등 포괄임금약정을 체결할 실질적 필요성이 없으며 ③ 정액의 월급여액이나 일당임금 외에 추가로 어떠한 수당도 지급하지 않기로 하거나 특정한 수당을 지급하지 않기로 하는 합의가 있었다고 객관적으로 인정되지 않는 경우일 것이다. 즉 실제로는 기본임금과 법정수당을 구분하지 않은 정액급여가 지급되었으나, 이는 기본급과 법정수당을 구분하여 지급하도록 정하고 있는 단체협약, 취업규칙 등에 명확히 반하고, 근로시간 산정이 가능할 뿐 아니라 정액급여 외에 추가로 수당을 지급하지 않기로 하는 합의가 인정되지도 않는 경우들일 것이다.

무효인 퇴직금 분할 약정에 기하여 지급된 퇴직금 명목 금원의 성격에 대하여 대법원 2008다9150 판결은 ① 퇴직금 제도를 강행법규로 규정한 입법 취지를 감안할 때, 임금과 구별하여 추가로 퇴직금 명목으로 일정한 금원을 실질적으로 지급할 것을 약정한 경우에 한하여 공평의 원칙상 이미 지급된 퇴직금 명목의 금원을 부당이득이라고 볼 수 있고, ② 그 실질은 임금을 정한 것에 불과하고 사용자가 퇴직금 지급을 면탈하기 위하여 퇴직금 분할 약정의 형식만을 취한 경우에는 임금으로 보아야 한다고 판단하였다.

이러한 법리들을 참조하면 다음과 같은 근거에서 기지급된 정액급여 중 법정수당에 상당하는 금액⁸³⁾을 부당이득으로 볼 수는 없다.

83) 이미 지급된 정액급여 전부를 부당이득으로 보는 것은 불가능하다. 이는 기본급도 지급하지 않았다는 의미이기 때문이다.

① 정액급 포괄임금제의 경우 그 성립이 부정되는 경우는 강행규정인 근로기준법, 단체협약, 취업규칙 등에서 기본급과 법정수당을 구분하여 지급하도록 명백히 정한 것에 정면으로 반하고, 정액급여 외에 추가로 수당을 지급하지 않기로 하는 합의가 인정되지도 않으며, 실제로 기본급과 법정수당이 구분되지도 않으므로 대법원 2007다90760 전원합의체 판결, 대법원 2008다9150 판결 등이 부당이득이라고 볼 수 있다고 판단한 경우(☞임금과 구분되는 퇴직금 명목의 금원이 실질적으로 지급된 경우)에 해당하지 않는다.

② 퇴직금 분할 약정 사안은 분할하여 지급된 퇴직금 명목의 금원을 부당이득이라고 보아 근로자가 사용자에게 반환해야 한다고 보더라도 근로자가 적법하게 산정한 퇴직금을 청구하는 것이 전혀 어렵지 않으므로 근로자에게 부당하게 불이익을 가하고 사용자에게 부당한 이익을 주는 것이라고 볼 수 없는 경우가 대부분이다. 오히려 임금과 구별되는 퇴직금 명목의 금원을 실질적으로 지급한 것으로 평가되는 경우에도 이를 부당이득으로 보지 않으면 사용자가 실질적으로 중복하여 퇴직금을 지급하는 셈이 되므로 공평의 원칙상 부당하다고 볼 수도 있다. 대법원도 이를 고려하여 이와 같은 경우에는 부당이득이라고 평가한 것으로 이해된다. 그러나 포괄임금제 사안은 전혀 다르다. 포괄임금제의 성립 자체가 부정된 경우는 실제 근로시간 산정이 가능함에도 불구하고 사용자는 포괄임금제 도입을 이유로 근로시간을 기록하지 않은 경우가 대부분일 것이다. 이 경우 근로시간이 관리되지 않고 있었기 때문에 근로자는 실제 연장근로시간 등을 산정하여 법정수당을 청구하는 것이 매우 어려운 경우가 대부분일 것이다. 이런 경우에도 기지급한 금원 중 법정수당에 해당하는 금액을 부당이득으로 보아 근로자가 사용자에게 반환하고, 근로자는 다시 법정수당을 산정(사용자가 근로시간을 기록하지 않아 실제 근로시간 증명이 매우 어려움)하여 청구하라고 하는 것은 공평의 원칙에 반한다.

③ 실제로 정액급여 중 기본임금과 법정수당을 구분할 방법도 없다.

역산하는 방법으로 기본임금을 산정할 수는 있으나, 그 역산 방법 자체가 법정수당이 근로기준법의 기준에 맞게 모두 지급되었음을 전제로 하는 것인데, 그렇게 전제할 법률적 근거는 존재하지 않는다.

이와 같이 정액급 포괄임금제의 성립 자체가 부정되는 경우라면 이는 단순히 법정수당을 지급하지 않은 것(임금체불)으로 보는 것이 타당하지 법정수당을 실질적으로 지급하였고 단지 그 법정수당이 정액급여 안에 포함되어 있어 구분하기 어려운 것일 뿐이라고 이해할 수는 없다. 따라서 이미 지급된 정액급여는 부당이득이 아닌 임금이고 주된 쟁점은 “통상시급” 산정 방법이라고 보아야 한다.

2) 다른 사정이 증명되지 않는 한 기지급된 정액급 전부를 통상임금으로 보아야 함

정액급으로 지급한 급여가 임금이지만 법정수당을 지급한 것으로서의 의미가 없다면 기지급액 전액을 소정근로(1일 8시간)의 대가인 통상임금으로 보아야 할 것이다. 사용자는 이 금액 전부를 기준으로 통상시급을 산정하여 법정수당(☞차액이 아니라 전액)을 지급해야 한다. 특히 정액급여에 대응하는 근로시간을 사전에 정하지 않은 경우에는 이미 지급된 정액급여는 소정근로의 대가라고 보는 방법 외에는 없어 보인다.

대법원 2015다73067 전원합의체 판결은 월 고정급을 소정근로시간(1일 8시간)뿐 아니라 사전에 약정한 근로시간 전체에 대한 대가(다만 가산율만 제외함)로 판단한 것으로 보이기 는 한다. 그러나 위 전원합의체 판결은 고정수당이 어느 정도의 근로에 대한 대가인지에 대한 당사자의 의사가 정확히 확인되지 않는 경우에 적용되는 것이다. 그러나 정액급 포괄임금제의 성립 자체가 부정된 경우라면 기존에 지급된 정액급여는 소정근로의 대가일 뿐이라고 봄이 타당하다. 사전에 약정한 연장근로에 대하여 연장근로 그 자체에 대한 대가(100%)는 지급하고(☞정액급여에 포함되어 있음), 50%의 가산임금은 지급하지 않았다는 것(☞정액급여에

포함되지 않음)고 보는 것은 일반적인 노사 당사자의 의사라고 볼 수 없고, 그렇게 의사를 해석할 만한 별도의 근거가 있는 경우에만 가능하다고 본다. 그러한 근거가 없다면 연장근로에 대한 임금(150%) 전부를 지급하지 않았다고 보는 것이 객관적이고, 이 경우 기지급된 정액급여는 연장근로를 포함하여 사전에 약정한 근로시간 전부가 아니라 소정근로(1일 8시간)에 대한 대가라고 보는 것이 타당하다. 특히 매월의 실제 근로시간이 불규칙함에도 불구하고 매월 동일한 금액이 정액급 포괄임금 명목으로 지급되었다면 소정근로일의 1일 8시간 근로에 대한 대가라고 해석할 수밖에 없다고 보인다.

서울고등법원 2019. 8. 20. 선고 2018나2045580 판결이 포괄임금제 성립을 부정하면서 기지급액 중 통상임금에 해당하는 임금항목들을 209시간으로 나눈 값을 통상시급으로 계산하여 이와 같은 입장을 취한 것으로 보인다. 이 서울고등법원 판결은 대법원 2025. 9. 11. 선고 2019다273803 판결로 상고기각 확정되었는데 대법원은 서울고등법원의 위 판단을 수긍한 것으로 보인다.⁸⁴⁾

[서울고등법원 2019. 8. 20. 선고 2018나2045580 판결]

(2) 피고가 지급할 금액

기본급, 위험수당, 연구수당, 가족수당(본), 차량유지(과), 식대(비과세), 통신비, 업무수당, 특진수당, 전공의업무성과급, 전공의당직비, 당직비, 급여소급, 상여금, 명절상여, 상여소급, 고정시간외수당을 포함시키고 수련보조수당, 파견수당을 제외한 월급금액을 209시간[= (1주당 기준근로시간 40시간 + 주휴일 근로간주시간 8시간) × (365일 / 7일) ÷ 12개월]으로 나누는 산식에 따라 시간급 통상임금을 계산하면 별지 1 내지 3의 각 [표4]의 “시간급 통상임금”란 기재 금액이 되고, 이러한 시간급 통상임금 및 별지 1 내지 3의 각 [표3]에 기재된 초과시간과 총 야간시간을 기초로 근로기준법이 정한 가산율을 반영하여 법정

⁸⁴⁾ 대법원 2019다273803 판결문 중 포괄임금 성립을 부정하면서(제2 상고이유), 원심이 택한 “시간급 통상임금 산정방법 등”에 법리 오해가 없다고 판단한 제3 상고이유 부분 참조.

수당을 계산하면 별지 1 내지 3의 각 [표5]의 “총 가산임금”란 및 “합계”란 기재 금액이 된다.

피고는, 원고들과 사이에 수련시간을 1주당 80시간으로 정하였고, 원고들은 1주당 80시간 전체에 대한 대가로 급여를 지급받았으므로, 월급금액을 월 209시간으로 나누는 산식이 아니라 $\frac{\text{월급금액}}{209\text{시간} + \text{월간 시간외근로시간} \times 1.5}$ 의 산식에 의하여 시간급 통상임금을 계산하여야 하고, 이 경우 분모는 470시간(= 209시간 + 174시간 $\times$ 1.5)⁸⁵⁾이 된다고 주장한다. 그러나, 피고의 위 주장은 원고들의 급여에 1주당 80시간까지의 시간외근로수당이 포함되어 있음을 전제로 하는 것인데, 이와 같이 볼 수 없다는 점은 앞에서 살핀 바와 같으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

[대법원 2025. 9. 11. 선고 2019다273803 판결]

2. 월 급여에 포함된 임금의 범위 및 포괄임금약정의 성립 여부(제2 상고이유, 제3 상고이유 중 일부 관련)

...(생략)...

나. 원심은 그 판시와 같은 이유로 피고가 지급한 급여가 1주 40시간의 근로에 대한 대가라고 전제한 후, 위 급여 외에 1주 40시간을 초과하는 근로에 대한 연장근로수당이나 야간근로수당을 별도로 지급하지 않는다는 묵시적 포괄임금약정이 성립되었다고 보기 어렵다고 판단하였다.

다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이러한 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 근로계약의 해석이나 묵시적 포괄임금약정 성립 등에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니하거나 판단을 누락함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 통상임금의 범위 및 당직비 등의 공제 여부(제3 상고이유 중 일부 관련)

85) (판결문의 내용은 아닌 필자 주) 포괄임금약정 성립이 부정된다면 가산임금까지 포함한 대가로 정액급여가 지급되었다고 보는 것은 불가능하다. 원심 판결문만을 본다면 상고이유가 정확히 제기되지 않았을 가능성도 있어 보인다.

원심은 그 판시와 같은 이유로 원고들에게 지급된 업무수당, 전공의 업무성과급, 상여금, 상여소급, 명절상여, 전공의당직비, 당직비, 고정 시간외수당, 연구수당, 통신비, 특진수당 등이 소정근로의 대가로서 정기적·일률적·고정적으로 지급된 통상임금에 해당한다고 판단하고, 전공의당직비, 당직비, 고정시간외수당이 연장·야간근로수당의 일부로 지급된 것이어서 원고들의 연장·야간근로수당 청구액에서 공제되어야 한다는 피고의 주장을 배척하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 고정성을 통상임금의 개념적 징표로 본 것은 적절하다고 볼 수 없으나(대법원 2024. 12. 19. 선고 2020다247190 전원합의체 판결 등 참조), 위 각 수당 등이 통상임금에 해당한다는 원심의 결론은 정당하다. 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 통상임금의 범위나 시간급 통상임금 산정방법 등에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3) 기지급된 정액급은 사전에 약정한 근로시간 전부에 대한 임금이라고 보는 것이 타당한 경우도 있음

한편, 정액급 포괄임금에 대응하는 연장근로시간 등을 구체적으로 사전에 약정한 경우 정액급 전부가 통상임금은 아니고 사전에 약정한 근로시간에 전체에 대하여 지급된 것으로 보아야 하는 경우도 있을 수 있다. 이 경우 근로자는 기지급된 정액급여는 소정근로시간과 사전에 약정한 연장근로 그 자체에 대한 임금(100%)이므로, 나머지 금원 즉, 사전에 약정한 연장근로에 대한 가산임금(50%)과 사전에 약정한 연장근로를 초과한 연장근로시간에 대한 임금(150%)을 청구할 수 있다.

예를 들어 사전에 1일 10시간의 근로(=8시간 소정근로 + 2시간 연장근로)를 하기로 약정하고 법정수당과 기본급의 구분 없이 월 100만 원을 지급한 경우, 위 100만 원은 앞에서 본 2)의 경우와 같이 해당 월의 소정근로일 중 8시간의 근로에 대한 임금이라고 보는 것이 일반적인 의사 해석이다(특히 매월의 실제 근로시간이 불규칙함에도 불구하고 월 100만 원이 고정적으로 지급된 경우에는 더욱 그러하다). 그러나 노사 당사자

가 월 100만 원은 10시간의 근로에 대한 임금이라고 정한 경우에는 10시간 근로(다만 가산율은 제외)에 대한 임금으로 지급된 것으로 보는 것이 타당할 것이다. 이는 의사해석의 문제이다. 이 경우 100만 원은 해당 월의 소정근로일 중 1일 8시간에 대해서가 아니라 10시간에 대하여 지급된 것으로 평가되므로 통상임금에 포함되는 월 급여액은 100만 원이 아니라 약 69만 원⁸⁶⁾이 될 것이다. 이 경우 근로자는 월 69만 원을 기초로 산정한 통상임금에 근거하여 사전에 약정한 매일 2시간의 연장근로에 대한 가산임금(50%)과 이를 초과하는 연장근로에 대한 150%의 임금을 청구할 수 있다.

인천지방법원 2024. 11. 19. 선고 2022나78152 판결(미상고 확정)이 이러한 방식으로 통상시급을 산정한 것으로 보인다.

[인천지방법원 2024. 11. 19. 선고 2022나78152 판결(미상고 확정)]

...(생략)... 이른바 포괄임금제에 대한 합의가 있었다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다[다만, 아래 다. 1) 나)항에서 보는 바와 같이 피고가 매월 정기적·일률적·고정적으로 지급한 급여에는 연장근로시간 및 주휴시간에 대한 대가도 포함되어 있다고 보이는데, 그 부분은 시간급 통상임금 산정에 고려하기로 한다].

...(생략)... 원고들이 매월 정기적·일률적·고정적으로 지급받은 급여(별지1 계산표 중 ‘통상임금 산정기준 월 급여’란 기재 금액)에는 소정근로의 대가뿐 아니라 연장근로의 대가와 주휴수당도 포함된 것으로 봄이 상당하다. 따라서 원고들의 시간급 통상임금은 소정근로시간, 연장근로시간, 주휴시간을 합한 시간 수로 나누는 방식으로 산출하여야 한다.

...(생략)...

결국 시간급 통상임금 산정기준이 되는 시간 수는 월 평균 소정근로시간에 연장근로시간, 주휴시간을 합한 월 176.3시간(= 소정근로시간 121.6시간 + 연장근로시간 30.4시간 + 주휴시간 24.3시간)으로 보는 것이 타당하다.

⁸⁶⁾ 월 100만 원을 1주 5일, 1일 10시간 근로 및 주휴(8시간)에 대한 대가로 본 후, 1일 8시간의 대가(주휴시간 제외)를 산정하면 약 월 69만 원(≈68.9만 원)이 된다.

4) 기타: 최저임금법 위반 판단을 위한 비교대상 임금

한편 정액급 포괄임금제의 성립 자체가 부정된 경우라면 대체로 실제 근로시간 산정이 가능한 경우가 많을 것이어서 법정수당을 청구할 수 있는 경우가 많겠지만, 실제 근로시간 산정이 불가능한 경우도 있을 수 있는데 그 경우에는 보장시간약정을 인정할 수 있는지를 검토해 보아야 한다.⁸⁷⁾ 만일 보장시간약정도 인정되기 어렵다면 근로기준법상 법정수당을 청구하는 것이 불가능하고 최저임금법이 사실상 유일한 강행규정이 된다. 이 경우 포괄임금제의 성립 자체가 부정되었으므로 기지급된 정액급여 전부를 비교대상 임금으로 볼 수밖에 없는데, 정액급여 전액을 기준으로 최저임금법 위반을 판단하면 최저임금법 위반이 아니게 될 가능성도 높아서 정액급 포괄임금제의 성립이 부정되는 것이 근로자에게 유리한 결과가 아닌 경우도 존재할 수 있게 된다.

(2) 정액급 포괄임금제가 성립하였으나 무효가 되는 경우 기지급된 정액급여의 성질

대법원이 판시한 포괄임금제의 유효 여부 판단 기준을 다시 살펴 본다.

[대법원 2024. 2. 8. 선고 2018다206899 판결]⁸⁸⁾

① 근로시간, 근로형태와 업무의 성질을 고려할 때 근로시간의 산정이 어려운 것으로 인정되는 경우에는 포괄임금제에 의한 임금 지급계약을 체결하더라도 그것이 달리 근로자에게 불이익이 없고 여러 사정에 비추어 정당하다고 인정될 때에는 유효하다(대법원 2002. 6. 14. 선고 2002다16958 판결, 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008다6052 판결 등 참조).

② 그러나 위와 같이 근로시간의 산정이 어려운 경우가 아니라면 근로기준법상의 근로시간에 관한 규정을 그대로 적용할 수 없다고 볼 만

⁸⁷⁾ 근로시간 산정이 가능한 경우에도 보장시간약정제가 인정되는 사안이라면 그에 기초한 청구 역시 가능하다.

⁸⁸⁾ ①, ②표시는 판결문에 없으나 필자가 임의로 추가한 것이다.

한 특별한 사정이 없는 한 근로기준법상의 근로시간에 따른 임금 지급의 원칙이 적용되어야 하므로, 이러한 경우에 앞서 본 포괄임금제 방식의 임금 지급계약을 체결한 때에는 그것이 근로기준법이 정한 근로시간에 관한 규제를 위반하는지를 따져, 포괄임금에 포함된 법정수당이 근로기준법이 정한 기준에 따라 산정된 법정수당에 미달한다면 그에 해당하는 포괄임금제에 의한 임금 지급계약 부분은 근로자에게 불이익하여 무효라 할 것이고, 사용자는 근로기준법의 강행성과 보충성 원칙에 의하여 근로자에게 그 미달되는 법정수당을 지급할 의무가 있다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008다6052 판결, 대법원 2020. 6. 25. 선고 2015다8803 판결 등 참조).

1) 근로시간 산정이 가능함에도 불구하고 포괄임금 약정을 체결하였다는 점만을 이유로 전부 무효로 보는 경우

위 대법원 판결이 근로시간 산정이 가능함에도 불구하고 포괄임금 약정을 체결하였다는 점만을 이유로 포괄임금 약정 전부가 무효라고 판단한 것으로 보기는 어렵고, 실제로 그렇게 판단한 판결도 찾을 수 없다. 그러나 정액급제의 경우 근로기준법의 적용을 사실상 불가능하게 하는 것이므로 더욱 엄격한 판단이 필요한 점을 고려하면 적어도 근로시간 산정이 가능함에도 불구하고 정액급 포괄임금약정을 체결한 경우에는 그 사유만으로도⁸⁹⁾ 전부 무효라고 봄이 타당하다.⁹⁰⁾

근로시간 산정이 가능함에도 불구하고 정액급 포괄임금약정을 체결한 경우, 사용자의 의사는 “법정수당을 구분하여 지급하는 것이 충분히 가

89) 근로기준법 시행령은 임금 및 가족수당의 계산기초가 되는 사항(제27조 제1항 제5호), 연장·야간·휴일근로시간 수(제27조 제1항 제8호)을 임금 대장의 필수적 기재사항으로, 임금의 구성항목별 금액의 계산방법(연장근로, 야간근로 또는 휴일근로의 경우에는 그 시간 수를 포함한다)(제27조의2 제5호)을 임금명세서의 필수적 기재사항으로 정하고 있다.

90) 임상민, 앞의 글, 107면도 같은 취지로 보인다. 나아가 임상민은 약정한 정액급을 기본임금으로 간주하는 해석이 필요하다고 하는데 여기서 기본임금은 이 글에서 말하는 통상임금으로 이해된다.

능하지만 그렇게 하지 않겠다”는 것인데 이는 법정수당을 지급하지 않겠다는 의사로 보아야 한다. 또한 실제로 근로시간 산정이 가능함에도 불구하고 정액급 포괄임금약정을 체결한 경우는 정액급 포괄임금제의 성립 자체가 부정된 경우와 유사하므로 그 효과도 유사하게 부여할 필요가 있다. 즉 앞에서 검토한 바와 같이 정액급여 전부를 통상임금 또는 사전에 약정한 근로시간에 전체에 대한 임금이라고 볼 수 있다. 만일 입법으로 정액급 포괄임금제를 무효로 규정하는 경우에는 논란을 방지하기 위하여 기지급된 정액급여는 통상임금 등으로 간주한다는 등의 내용을 규정할 필요도 있을 것이다.

이하에서 이 쟁점에 관한 판단이 포함된 일본 최고재판소 판결과 의성지원 판결을 검토한다. 일본 최고재판소 판결⁹¹⁾은 정액급 포괄임금제 합의를 인정하지 않는 쪽에 기울어져 있다. 테크 재팬 판결[テックジャパン事件・最高裁 2012・3・8・労判 1060-5]은 파견근로자가 파견사업주에 대하여 시간외근로수당을 청구한 사건으로, 기본급을 월액 41만 엔으로 하고, 1개월간의 근로시간 합계가 180시간을 초과한 경우에는 그 초과한 시간분의 수당을 지급하나, 월간 총 근로시간이 140시간에 이르지 못한 경우 공제한다는 취지의 약정이 이루어진 사안이다. 취업규칙에서 근로시간을 1일 8시간, 휴일을 토·일요일 및 공휴일과 연말연시 기타 회사가 정하는 휴일로 정하고 있었다. 쟁점은 180시간 이내의 시간외근로에 대하여 연장근로수당이 발생하는지 여부이다. 최고재판소는 법정수당과 기본임금이 구분되지 않는 정액급 포괄임금약정이 노동기준법을 위반했다고 판단하면서 정액급으로 지급된 임금 총액(월 41만 엔)을 모두 기본급으로 보아 할증임금을 지급해야 한다고 판단하였다. 즉 앞의 「(1). 2)항」과 같이 월 41만 엔을 소정근로 그 자체에 대한 대가라고 판단한 것으로 보인다.

91) 테크 재팬 판결을 포함하여 일본 최고재판소 판결에 대해서는 최석환, 근로계약 과정에서 나타나는 당사자 합의의 해석(일본의 포괄임금제 관련 판결을 소재로 한 검토), 「노동법연구」 제41권, 서울대학교노동법연구회, 2016. 9. 261~276면 참조

대구지방법원 의성지원 2022. 12. 23. 선고 2020가합10199 판결은 다음과 같이 ① 실근로시간 산정이 어렵지 않을 뿐 아니라 ② 일부⁹²⁾ 기간이 최저임금법 위반이라는 점을 근거로 정액급 포괄임금약정 전부가 무효라고 판단하였다. 비록 2심 판결이 해당 사건에서는 포괄임금제가 유효하다고 판단하여 위 의성지원 판결 자체는 파기되었지만 의성지원의 이러한 법리 판단은 참조할 여지가 있다. 한편 위 의성지원 판결은 정액급 포괄임금 약정이 무효인 경우 그 전부를 기본급으로 보아 통상시급을 산정하였는데 그 구체적인 계산 방법을 보면 앞의 「(1). 3)항」의 방식으로 보인다. 즉 기지급된 정액급여는 소정근로시간, 연장근로시간(가산을 제외), 주휴시간에 대한 대가라고 판단한 것으로 보인다.

**[대구지방법원 의성지원 2022. 12. 23. 선고 2020가합10199 판결
(2심에서 파기)]**

결국 실근로시간의 산정이 어려운 경우에 해당하지 않을 뿐만 아니라 일부 기간의 임금이 최저임금에 미달하여 근로자에게 불이익하기까지 한 위 포괄임금약정은 무효이다.

정액급제로 정한 포괄임금약정이 무효일 경우 그 포괄임금약정이 규율하던 근로관계를 어떻게 정리하여야 할지가 문제되는데, 이에 관해 ① ‘실근로시간’을 산정한 후 그에 따라 기본급과 제 수당을 역산한 다음 최저임금법에 위배된 부분이 있는지를 살펴 추가 법정수당의 지급의무 존부를 판단하는 방법과 ② 전체 급여에서 기본급과 법정수당을 구분하는 것이 곤란하므로 정액급제로 지급된 포괄임금 전부를 기본급으로 보아 이를 토대로 법정수당을 추가로 산정하는 방법을 상정할 수 있다.

첫 번째 방법을 따를 경우 사용자의 편의에 따라 위법한 포괄임금약정이 체결되었음에도 오히려 근로자에게 최저임금만을 기본임금으로 지급받을 것을 강요하며 그 불이익을 근로자에게 전가하는 그릇된 결과가 초래될 수 있는 점, 두 번째 방법의 적용이 경제적 여건이 뒷받

⁹²⁾ 청구기간 28개월(2017. 6. 1. ~ 2019. 9. 30.) 중 15개월(2018. 1. 1. ~ 2018. 6. 30. 및 2019. 1. 1. ~ 2019. 9. 30.)이 최저임금법 위반이었던 것으로 보인다.

침되는 한도에서 근로자가 인간다운 생활을 할 수 있도록 가능한 모든 지원을 다하고자 하는 노동관계법령의 이념에 보다 부합하는 점 등을 고려하면, 정액급제로 정한 포괄임금약정이 무효일 경우 두 번째 방법과 같이 지급된 포괄임금 전부를 기본급으로 보아 이를 토대로 법정수당을 추가로 산정하도록 하는 것이 보다 타당한 결론으로 보인다(피고가 운전근로자들의 실근로시간을 산정할 수 있는 객관적 자료를 제출하지 않고 있는 이 사건에서는 기본급과 제수당을 역산할 수 없어 첫 번째 방법을 따를 수 없기도 하다). 따라서 피고가 제1, 2기간에 원고들에게 지급한 임금 전부를 기본급으로 보아야 하므로, 피고는 원고들에게 아래 제5항과 같이 재산정될 제1, 2기간의 시간급 통상임금에 따라 추가로 산정한 연장근로수당과 주휴수당을 지급하여야 한다.

2) 근로기준법 또는 최저임금법 위반을 이유로 일부 무효가 되는 경우

정액급 포괄임금제가 근로기준법 위반을 이유로 무효가 되는 경우는 실제 근로시간 산정이 가능한 경우이다. 이때 실제 연장근로시간보다 적은 시간을 전제로 정액급 포괄임금제가 성립하였다면 근로자에게 불리한 부분만 무효가 되는 것이어서(근로기준법 제15조 제1항) 기존에 지급된 정액급여 중 법정수당에 상당하는 금액이 법정수당으로서의 성질 자체를 상실한다고 보기 어렵다. 이 경우 근로자들은 실제 연장근로시간 등을 전제로 적법하게 산정한 법정수당과 기지급액의 “차액”을 청구할 권리가 있다.

실제 근로시간 산정이 불가능한 경우에는 근로기준법에 따른 연장근로수당 등의 산정이 불가능하고, 결과적으로 최저임금법 적용만 가능하다(최저임금법 위반 판단 방법은 앞에서 본 바와 같다). 이 경우에도 최저임금법 위반 부분에 한하여 무효가 되는 것이므로, 기지급된 정액급여 중 법정수당에 상당하는 금액이 법정수당으로서의 성질 자체를 상실한다고 보기 어렵다. 근로자들은 무효가 된 범위 내에서의 청구(즉, 최저임금법 위반으로 인한 비교대상 임금 차액 청구 및 그로 인한 통상임금 증액으로 인한 법정수당 차액 청구)만 가능하다.

VII. 나가며

이상에서 포괄임금에 성립과 효력에 관한 기본법리 및 그 법리의 적용 범위, 정액급 포괄임금제를 중심으로 한 최저임금법 위반 및 그 차액 산정 방법, 정액급 포괄임금제가 성립하지 않거나 무효인 경우 기지급된 금원의 성질에 대하여 검토하였다. 실무상 중요한 쟁점인데 이에 대한 깊은 검토는 없었던 쟁점들이다. 포괄임금제에 대한 비판에 따라 대법원이 포괄임금제의 성립과 효력 요건을 엄격하게 판단하고 있는 추세이기는 하나, 실제 근로시간 단축이라는 시대적 요청의 흐름을 따라가지 못하고 있다고 보인다. 새 정부에서도 근로시간 단축에 관한 여러 논의가 진행 중이고, 포괄임금제에 관한 내용도 그에 포함되어 있다. 정액급 포괄임금제는 무효로 규정하고, 정액수당 포괄임금제는 제한적인 범위 내에서 그 효력을 인정하는 방향일 것으로 추측된다.⁹³⁾ 기본임금을 따로 정하지 않은 정액급 포괄임금제는 근로기준법의 적용을 사실상 불가능하거나 매우 어렵게 만들고, 최저임금법이 사실상 유일하게 적용되는 강행규정인 경우가 대부분이다. 게다가 이 글에서 지적한 바와 같이 그 최저임금법 위반 및 차액 계산 방법마저도 매우 어려워서 관련 문헌 및 법원 판결에서도 상당한 오류를 범할 정도이다. 이러한 정액급 포괄임금제를 계속 유지하는 것은 어떠한 합리적 이유도 없다고 보이는데, 대법원이 정액급 포괄임금제를 무효로 선언하지 못하고 있으므로 입법적 조치가 필요한 시점이다.

(논문발표: 2026. 2. 21. 논문접수 2026. 3. 2. 심사의뢰 2026. 3. 4. 게재확정 2026. 3. 19.)

⁹³⁾ 2025. 12. 30. 발표된 「실노동시간 단축 로드맵 추진단」 논의결과 대국민보고 보도자료(12면)에 의하면 “포괄임금 오남용 방지(정액급제 개선 등)”이라는 내용 하에 “노동자 동의 + 불리하지 않은 경우 예외적 허용(사전에 수당을 포함해서 약정하되, 약정시간에 미달해도 전액을 보장하는 반면, 약정시간을 초과하면 차액 지급)”이라고 되어 있다. 여기서 정액급제는 정액수당 포괄임금제와 대비되는 의미에서 정액급 포괄임금제보다는 포괄임금제 일반을 통칭한 것으로 보인다.

참고문헌

- 강경미, 주휴수당이 최저임금 지급대상인지 여부, 「대법원판례해설」, 제141호, 법원도서관, 2024.
- 강성태, 포괄임금제의 노동법적 검토, 「노동법연구」, 제26호, 서울대학교 노동법연구회, 2009.
- 고용노동부, 「실노동시간 단축 로드맵 추진단」 논의결과 대국민보고 보도자료, 2025. 12. 30.
- 고용노동부, 「유연근로시간제 가이드」, 2018. 6.
- 김현수, 「최저임금법」, 법원사, 2018.
- 노동법실무연구회, 「근로기준법 주해 Ⅲ」, 박영사, 2025.
- 박순영, 근로기준법상 근로시간의 규제와 포괄임금제, 「대법원판례해설」 제83호, 법원도서관, 2010.
- 임상민, 포괄임금제의 성립 및 유효요건, 「인권과 정의」, 제502호, 대한변호사협회, 2021. 12.
- 정재현, 포괄임금제의 재조명, 「사법」, 제15호, 2011. 1.
- 최석환, 근로계약 과정에서 나타나는 당사자 합의의 해석(일본의 포괄임금제 관련 판결을 소재로 한 검토), 「노동법연구」, 제41권, 서울대학교 노동법연구회, 2016. 9.
- 하갑래, 포괄임금제의 내용과 한계, 「노동법학」, 제29호, 한국노동법학회, 2009.

<Abstract>

A Review of Practical Issues Concerning the Comprehensive Wage System

Taewook Kim *

The legal principles established in Supreme Court Decision 2010. 5. 13., 2008da6052, which are regarded as providing the fundamental framework for the “Comprehensive Wage System,” are currently being applied uniformly to all comprehensive wage cases regardless of the cause of action or means of attack. This practice is inappropriate. It is more reasonable to limit the application of these principles to cases which are based on the claim that the employee performed actual overtime, night, or holiday work exceeding the agreed-upon working hours. Since the calculation of actual overtime hours is not a point of contention, the aforementioned legal principles are inapplicable to: claims for allowances necessitating only the confirmation of prescribed labor, claims for statutory allowance differentials based on the recalculation of ordinary wages, and claims for differentials arising from Minimum Wage Act violations.

Meanwhile, applying simplified practical methods, as used in general minimum wage cases, to determine whether a comprehensive wage system violates the Minimum Wage Act and to calculate the resulting difference carries a high risk of error. In the case of Fixed-Sum Comprehensive Wage Systems, regarding claims for periods prior to

* Attorney at Law, Law Firm Yeooneun.

December 31, 2018, it appears that both the relevant literature and the majority of lower court rulings have erred in calculating the comparative hourly wage and the wage gap for the purpose of determining Minimum Wage Act violations. Even for periods after January 1, 2019, calculating in the same manner as general minimum wage cases is highly likely to result in errors, not only for fixed-sum but also for Fixed-Allowance Comprehensive Wage Systems. To ensure accuracy, the determination of whether a comprehensive wage system violates the Minimum Wage Act and the calculation of any resulting difference must follow the principled stepwise methods prescribed by the Minimum Wage Act and its enforcement decrees (i.e., calculating the comparative hourly wage, then separately determining the difference resulting from the Minimum Wage Act violation and the subsequent Labor Standards Act violation).

If the formation of a Fixed-Sum Comprehensive Wage System is itself denied, the portion of the fixed pay corresponding to statutory allowances cannot be regarded as unjust enrichment. Unless other circumstances are proven, the fixed pay already provided should be viewed as ordinary wage (compensation for prescribed labor). Especially, fixed monthly payments made regardless of irregular working hours must be regarded as ordinary wage. But if the intent to provide compensation for the entirety of the pre-determined working hours is confirmed, it should be regarded as basic pay (compensation for the entire pre-determined hours, excluding the premium rate). In cases where working hours can be calculated yet a fixed-sum comprehensive wage agreement is concluded and its formation is recognized, it is appropriate to deem it entirely void for that reason alone; the fixed pay already provided in such cases should be evaluated identically to instances where the formation of the system is denied. In contrast, where the formation of a fixed-sum comprehensive wage system

is recognized but found partially void due to violations of the Labor Standards Act or the Minimum Wage Act, the inherent nature of the paid fixed sum as a statutory allowance is not necessarily denied.

Key Words: Method of determining the validity of the inclusive wage system, Distinction between the Fixed-Allowance System and the Fixed-Sum System, Determination of Minimum Wage Act Violations within the Comprehensive Wage System, The Legal Nature of Fixed Pay Already Provided